

以法为据 · 以理服人 · 以梦为岸

法治中国
良法善治
步履不停

法不止于条文
更在于对正义的追寻
愿你在考场上
写下心中的法治答案

以所学 致公义
以笔墨 赴理想

JUSTICE
RULE OF LAW
A BRIGHTER
TOMORROW

2026年 刑诉主观佛脚 100问

聚焦考点 · 梳理体系 · 强化表达

—— 从法理到案例 · 从知识到得分 ——

主讲人：向高申

以法之光
照亮前行的路



Justice
Rule of Law
A Brighter Tomorrow



扫码可直接收看视频课件

专题一：大纲新增与热点问题

大纲新增条文	新增条款（刑诉法 292 条的立法解释）
大纲新增考点	认罪认罚案件的审理程序
前沿改革热点	《监察法》修改
	《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》修改
	《人民检察院审查逮捕质效标准（试行）》
	《人民检察院审查起诉质效标准（试行）》
	《关于适用刑事缺席审判程序若干问题的规定》

新增条文：《全国人大常委会关于适用〈刑诉法〉292 条的立法解释》

- 问题 1：张三涉嫌贪污犯罪，潜逃境外。法院决定适用缺席审判程序审理。法院根据张三所在地法律允许的方式，通过公告方式送达。该送达是否合法？
- [法条索引]：《全国人大常委会关于〈中华人民共和国刑事诉讼法〉第 292 条的解释》
- [答题话术]

条文内容	《中华人民共和国刑事诉讼法》第 292 条中规定的“被告人所在地法律允许的其他方式”，是指被告人所在地的法律、判例、惯例、司法实践等所规定、承认、认可、接受的各种送达方式，包括但不限于邮寄、公告、公示、电子等送达方式。
命题分析	1. “所在地法律”包括：法律+判例+惯例+司法实践等所规定、承认、认可、接受的送达方式。 2. 其他方式包括但不限于：<u>邮寄、公告、公示、电子等送达方式</u>。 3. 送达对象：被告人（<u>传票+起诉书副本</u>）+被告人近亲属（<u>起诉书副本</u>）。 4. 依法送达是适用该类缺席审判程序的前提：<u>传票和起诉书副本送达后，被告人未按要求到案</u>，法院才进入开庭审理。

改革热点：《关于适用刑事缺席审判程序若干问题的规定》

- 问题 2-1：本案是否满足缺席审判的条件？
- [法条索引]《刑事诉讼法》291、296、297 条；《刑诉解释》
- [答题话术]

逃境外	[记忆要点]贪污只要在境外；危恐境外及时审，还要最高检核准。 [延申考点]犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯数罪，其中部分犯罪符合上述条件，可以对该部分犯罪案件适用缺席审判程序。共同犯罪案件中，<u>部分犯罪嫌疑人、被告人在境外</u>，符合上述条件，可以对该部分犯罪嫌疑人、被告人适用缺席审判程序。
得疾病	[记忆要点]疾病中止超 6 月，还要申请或同意。 [延申考点]“被告人患有严重疾病无法出庭”，是指被告人患有严重疾病导致其不能正常感知、理解、认识、表达而缺乏受审能力，无法出庭受审。法院应当就被告人是否患

	有严重疾病无法出庭作出认定，必要时，可以指派、聘请有专门知识的人进行鉴定、出具报告，并结合其他证据材料进行综合判断，依法作出认定。
已死亡	[记忆要点]被告死亡若缺席，除非因为他无罪；若是审监他死亡，有罪也能缺席判。

- 问题 2-2：缺席审判程序的相关转化问题。
- 场景 1：公诉程序中，被告人脱逃或者死亡的，法院又该如何处理？
- [法条索引]《刑诉解释》第 626；《刑诉法》298、291 条

(1) 公诉转没收	在审理案件过程中，被告人脱逃或者死亡，法院裁定中止审理或终止审理，符合违法所得没收程序条件的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。 [记忆要点]贪恐重大逃一年，死了直接收赃钱。
(2) 公诉转缺席	在审理案件过程中，被告人脱逃或者死亡，法院裁定中止审理或终止审理，符合缺席审判条件的，人民检察院可以按照缺席审判程序向人民法院提起公诉。 [记忆要点]贪贿只要在境外，危恐境外及时审，还要最高检核准。 [记忆要点]被告人死亡若缺席，除非因为他无罪；若是审监他死亡，有罪也能缺席判。

- 场景 2：特别程序审理中，在逃的被告人到案后，法院又该如何处理？
- [法条索引]《刑事诉讼法》第 295 条、《刑诉解释》第 625 条
- [答题话术]

缺席转普通 《刑事诉讼法》第 295 条	1. 在审理过程中，被告人自动投案或者被抓获的，人民法院应当重新审理。 [延申考点]审理过程中，被告人到案的，法院应当裁定终止审理。检察院依普通程序提起公诉的，法院依法受理后应当重新审理。法院重新审理的，一般由同一人民法院审理，原审人民法院系经指定管辖取得管辖权的，应当重新指定管辖。 2. 罪犯在判决、裁定发生法律效力后到案的，人民法院应当将罪犯交付执行刑罚。交付执行刑罚前，人民法院应当告知罪犯有权对判决、裁定提出异议。罪犯对判决、裁定提出异议的，人民法院应当重新审理。 [延申考点]罪犯对判决、裁定提出异议的，原审人民法院应当撤销原判决、裁定，并通知人民检察院。检察院依普通程序提起公诉的，法院应当重新审理。
没收转普通	在审理申请没收违法所得的案件过程中，在逃的犯罪嫌疑人、被告人到案的，人民法院应当裁定终止审理。人民检察院向原受理申请的人民法院提起公诉的，可以由同一审判组织审理。（《刑诉解释》第 625 条）

- 场景 3：因被告人严重疾病而缺席审理，被告人恢复受审能力了，该如何处理？
- [前沿问题]《刑事缺席审判程序若干问题的规定》第 20 条
- [答题话术]

审理中恢复	法院应当裁定终止缺席审判程序，依照刑事诉讼法普通程序的规定继续审理。
生效后恢复	对裁判提出异议的，法院应当撤销原判决、裁定，由作出缺席裁判的人民法院重新审理。

- 场景 4：缺席审判与没收违法所得的选择问题。
- [前沿问题]《刑事缺席审判程序若干问题的规定》第 17 条
- [答题话术]

情形 1	检察院认为犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，可以不经违法所得没收程序，直接依照刑事诉讼法第 291 条的规定提起公诉，法院经审查认为符合缺席审判程序适用条件的，依法审理作出裁判。
情形 2	缺席审理过程中，人民检察院申请撤回起诉，人民法院裁定准许撤诉的，检察院可以另行提出

	没收违法所得申请；被告人死亡的，人民法院应当裁定终止审理，除有证据证明被告人无罪并经缺席审理作出无罪判决的，人民检察院可以另行提出没收违法所得申请。
情形 3	检察院向法院先行提出没收违法所得申请的案件，人民法院经审理依法作出裁定后，人民检察院认为仍有必要启动缺席审判程序的，可以另行依照刑事诉讼法第 291 条的规定提起公诉，人民法院经审查认为符合缺席审判程序适用条件的，依法审理作出裁判，并对违法所得没收程序中尚未处置的相关涉案财产一并作出处理。

新增考点：认罪认罚案件的审理程序

- 问题 3：结合本案，谈谈你对“认罪认罚从宽”价值的理解和认识。
- [法条索引] “两高三部”《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》
- [答题话术]

基本概念	认罪认罚从宽，是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
价值分析	认罪认罚的价值分析如下： (1) <u>体现了公正基础上的效率观</u> 。在这一制度下，大多数被告人认罪案件，有望通过被告人的认罪认罚，实现审查起诉与法庭审理的简易化，缩减办案期限。 (2) <u>体现了现代司法宽容精神</u> 。既能够体现对犯罪嫌疑人、被告人权益的充分尊重，也有利于彰显刑事追诉的人文关怀。 (3) <u>探索形成非对抗的诉讼格局</u> 。这种格局使得刑事诉讼的部分环节得以简化或者省略，必将有效提升诉讼效率；减少刑事案件的信访申诉发生概率，从而有利于恢复被犯罪所破坏的社会关系。 (4) <u>实现司法资源的优化配置</u> 。推动案件繁简分流，解决案多人少的矛盾，对于缓解司法资源的有限性和日渐增长的案件数量之间的紧张关系有其特殊意义。
观点总结	总之，适用认罪认罚从宽制度，对准确及时惩罚犯罪、强化人权司法保障、推动刑事案件繁简分流、节约司法资源、化解社会矛盾、推动国家治理体系和治理能力现代化，具有重要意义。

- 问题 4：认罪认罚从宽原则的基本含义以及内涵和外延。
- [法条索引] “两高三部”《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第 6～9 条
- [答题话术]

何为认罪	(1) 犯罪嫌疑人、被告人如实供述自己的罪行。（主动供） (2) 对侦查机关已经掌握的犯罪事实，明确表示承认。（被动认）
	采分 1：承认指控的主要犯罪事实， <u>仅对个别事实情节提出异议，或者虽然对行为性质提出辩解</u> 但表示接受司法机关认定意见的， <u>不影响“认罪”的认定</u> 。 采分 2：犯罪嫌疑人、被告人犯数罪， <u>仅如实供述其中一罪或部分罪名事实的，全案不作“认罪”的认定，不适用认罪认罚从宽制度</u> ，但对如实供述的部分，人民检察院可以提出从宽处罚的建议，法院可以从宽处罚。
何为认罚	(1) <u>在实体上</u> ，自愿接受所认之罪在实体法上带来的刑罚后果。 (2) <u>在程序上</u> ，对诉讼程序简化的认可。
	采分 1：犯罪嫌疑人、被告人虽然表示“认罚”，却 <u>暗中串供、干扰证人作证、毁灭、伪造证据或者隐匿、转移财产，有赔偿能力而不赔偿损失</u> ，则不能适用认罪认罚从宽制度。 采分 2：犯罪嫌疑人、被告人享 <u>有程序选择权</u> ， <u>不同意适用速裁程序、简易程序的，不影响“认罚”的认定</u> 。

何为从宽	(1) <u>实体上</u>，给予相对更大程度上的从宽的幅度，以示对其认罪认罚的鼓励。 (2) <u>程序上</u>，即对犯罪嫌疑人、被告人适用限制人身自由程度更轻的强制措施、做出轻缓的程序性处理或者适用更为便利和减少诉累的诉讼程序。
	采分 1：<u>可以从宽不是一律从宽</u>； 采分 2：<u>主动认罪优于被动认罪，早认罪优于晚认罪，彻底认罪优于不彻底认罪，稳定认罪优于不稳定认罪</u>； 采分 3：<u>认罪认罚与自首、坦白不作重复评价</u>。

➤ 问题 5：分析认罪认罚的适用范围

➤ [法条索引]“两高三部”《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第 5、49、50 条

适用范围	根据《指导意见》第 5 条规定，认罪认罚从宽制度贯穿刑事诉讼全过程，适用于侦查、起诉、审判各个阶段。认罪认罚从宽制度没有适用罪名和可能判处刑罚的限定，所有刑事案件都可以适用，不能因罪轻、罪重或者罪名特殊等原因而剥夺犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪认罚获得从宽处理的机会。但“可以”适用不是一律适用，犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚后是否从宽，由司法机关根据案件具体情况决定。 [记忆要点]认罪认罚“无禁区”。
当庭认罪	根据《指导意见》第 49 条规定，被告人在侦查、审查起诉阶段没有认罪认罚，但当庭认罪，愿意接受处罚的，人民法院应当根据审理查明的事实，就定罪和量刑听取控辩双方意见，依法作出裁判。
二审认罪	根据《指导意见》第 50 条规定，被告人在第一审程序中未认罪认罚，在第二审程序中认罪认罚的，审理程序依照刑事诉讼法规定的第二审程序进行。第二审人民法院应当根据其认罪认罚的价值、作用决定是否从宽，并依法作出裁判。确定从宽幅度时应当与第一审程序认罪认罚有所区别。
单位认罪	[前沿问题]2026 年新修订的《认罪认罚指导意见》专门新增“单位犯罪案件的适用”规则，明确打破过去“认罪认罚主体只限自然人”的理解误区。 (1) 单位认罪：单位犯罪案件中，单位的诉讼代表人代表单位自愿如实供述单位犯罪事实，并积极协助调查，自愿接受处罚的，对涉案单位可以从宽处理。 (2) 责任者认罪：单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，愿意接受处罚的，可以从宽处理。

➤ 问题 6：共同犯罪中，部分被告人认罪，部分被告人不认罪，能否适用认罪认罚从宽制度？法院为了提高效率，简单将不认罪的被告人另案处理，仅以“认罪与否”为标准进行分案审理。该做法是否妥当？

➤ [前沿问题]新版《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第 12 条、第 46 条

➤ [答题话术]

场景 1	共同犯罪中，<u>部分被告人认罪认罚的，可以对其适用认罪认罚从宽制度</u>。共同犯罪案件中，认罪认罚的判断对象是具体的犯罪嫌疑人、被告人，而不是整个案件。<u>只要部分犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控犯罪事实没有异议，愿意接受处罚，就可以对其适用认罪认罚从宽制度。</u>
场景 2	不能简单以认罪和不认罪作为标准机械分案。共同犯罪案件中，部分被告人认罪认罚、部分被告人不认罪认罚的，<u>一般应当合并审理，并适用普通程序</u>。分案审理不是为了“凑速裁”“凑简易”，也不是为了把认罪被告人与不认罪被告人简单切开，而是<u>为了在人数众多、案情复杂、合并审理难以保证案件质量和诉讼效率时，进行必要的程序安排</u>。 因此，法院或者检察院仅以“认罪与否”为标准分案，通常不妥当。不能简单以认罪和不认罪作

为区分标准进行分案；首要分子、主犯，分案审理影响庭审调查的，一般也不宜分案处理。

- 问题 7：分析认罪认罚案件中对当事人的权利保障
- [法条索引] “两高三部”《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》
- [答题话术]

被告人法律帮助	根据《指导意见》第 10 条规定，犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪认罚， <u>没有辩护人的</u> ，人民法院、人民检察院、公安机关(看守所) <u>应当通知</u> 值班律师为其提供法律咨询、程序选择建议、申请变更强制措施等 <u>法律帮助</u> 。符合通知辩护条件的，应当依法通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。
被害人权益保护	根据《指导意见》16-18 条规定，（1） <u>应当听取</u> 被害人及其诉讼代理人的意见，并将犯罪嫌疑人、被告人是否与被害方达成和解协议、调解协议或者赔偿被害方损失，取得被害方谅解，作为从宽处罚的重要考虑因素。（2）被害人及其诉讼代理人 <u>不同意</u> 对认罪认罚的犯罪嫌疑人、被告人从宽处理的， <u>不影响</u> 认罪认罚从宽制度的适用。（3） <u>没有退赃退赔、赔偿损失</u> ，未能与被害方达成调解或和解协议的，从宽时应当予以酌减。（4） <u>由于被害方赔偿请求明显不合理，未能达成调解或者和解协议的，一般不影响从宽处理。</u>

- 问题 8：如果被告人认罪认罚签署具结书，有何程序要求？本案没有签署具结书是否违法？认罪认罚具结书，是否有约束力？最后具结书签署后，检察院向法院提出量刑建议的具体程序。
- [法条索引]《检察院办理认罪认罚案件开展量刑建议工作的指导意见》第 27 条、30 条
- [答题话术]

具结书签署程序	（1）应当在 <u>辩护人或者值班律师在场的情况下</u> 签署认罪认罚具结书。犯罪嫌疑人有辩护人的，应当由辩护人在场见证具结并签字， <u>不得绕开辩护人安排值班律师代为见证具结</u> 。辩护人确因客观原因无法到场的，可以通过远程视频方式见证具结。 （2）未成年犯罪嫌疑人签署具结书时， <u>其法定代理人应当到场并签字确认</u> 。法定代理人无法到场的，合适成年人应当到场签字确认。
未签具结书是否违法	（1） <u>没有法定原因而未签署的，属于程序不规范。</u> （2）存在法定免签情形的，不签署具结书不违法。例如 <u>犯罪嫌疑人是盲、聋、哑人，尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，或者未成年犯罪嫌疑人的法定代理人、辩护人对未成年人认罪认罚有异议的，不需要签署具结书。</u> <u>[记忆要点]盲聋哑、半疯傻、小孩法辩不认罚。</u>
具结书的法律效力	（1）具结书一经依法签署， <u>对控辩双方均具有约束意义</u> 。犯罪嫌疑人签署具结书后，没有新的事实、证据，或者犯罪嫌疑人没有反悔的， <u>人民检察院不得单方撤销具结书、变更量刑建议</u> 。这体现的是控辩协商的稳定性和犯罪嫌疑人的合理预期保护。 （2）犯罪嫌疑人签署具结书后反悔，不再认罪，或者不履行具结书中需要履行的赔偿损失、退赃退赔等义务的， <u>具结书失效，检察机关应当依法重新处理。</u>
量刑建议	（1）认罪认罚案件，人民检察院应当提出量刑建议。 <u>[前沿问题]办理认罪认罚案件，应当依法收集、审查量刑证据，就主刑、附加刑、是否适用缓刑、数罪并罚等，与犯罪嫌疑人及其辩护人或者值班律师充分沟通。</u> （2） <u>量刑建议可以另行制作文书，也可以在起诉书中写明。</u> （3）量刑建议 <u>一般应当为确定刑</u> 。对新类型、不常见犯罪案件，量刑情节复杂的重罪案件等， <u>也可以提出幅度刑量刑建议。</u>

- 问题 9：认罪认罚案件中，法院对检察院指控的罪名和量刑建议的处理问题。如果认罪

认罪案例中，检察院指控被告人盗窃罪，被告人也承认盗窃罪，法院认为指控的罪名与审理认定的罪名不一致，该如何处理？如果法院认为只是检察院量刑建议明显不当又该如何处理？

➤ [法条索引]《刑事诉讼法》第 201 条；

➤ [答题话术]

当然不采	根据《刑事诉讼法》第 201 条第 1 款规定，对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，<u>一般应当采纳</u>人民检察院指控的罪名和量刑建议，<u>但有下列情形的除外</u>：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。 [命题分析]上述情形，法院可以不采纳检察院指控罪名和量刑建议。法院应当听取人民检察院、被告人及其辩护人对审理认定罪名的意见，依法作出判决。
调整建议	根据《刑事诉讼法》第 201 条第 2 款规定，人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，<u>人民检察院可以调整量刑建议，人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。</u> [命题分析]此情形法院应当告知检察院，检察院可以调整量刑建议，该程序为前置程序。
[记忆要点]无罪、无责、违意愿、否认、不一或其他，量刑建议不采纳；量刑建议显不当，应当告知其调整，仍然不当依法判。	

➤ 问题 10：认罪认罚案件中，检察院的监督程序。被告人认罪认罚，检察院向法院提出了判 3 缓 4 的量刑建议，一审法院认为该量刑建议明显不当，直接判处被告人有期徒刑 2 年，人民检察院该如何监督？如果法院认为量刑建议明显不当，建议检察院调整，检察院拒绝调整，于是法院判处被告人有期徒刑 2 年，人民检察院又该如何监督？

➤ [答题话术]

程序违法	法院认为量刑建议明显不当， <u>未告知检察院调整</u> 量刑建议而直接作出判决的， <u>检察院一般应当以违反法定程序为由依法提出抗诉。</u>
量刑错误	法院认为量刑建议明显不当建议检察院调整，检察院 <u>不予调整</u> 或者调整后人民法院不予采纳，人民检察院认为判决、裁定 <u>量刑确有错误的，应当依法提出抗诉</u> ，或者根据案件情况， <u>通过提出检察建议或者发出纠正违法通知书等进行监督。</u>

➤ 问题 11：简述认罪认罚案件中，特殊情况下撤销案件、不起诉，需要满足什么条件。

➤ [法条索引]《刑事诉讼法》第 182 条；《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第 7 条；《公安部规定》第 188 条

➤ [答题话术]

原则规定	犯罪嫌疑人自愿如实供述涉嫌犯罪的事实，<u>有重大立功或者案件涉及国家重大利益的</u>，<u>经最高人民检察院核准</u>，公安机关可以撤销案件，人民检察院可以作出<u>不起诉决定</u>，也可以对涉嫌数罪中的一项或者多项不起诉。 [记忆要点]如实供述、大立功、高检核。
重大立功判断标准	是指犯罪分子有检举、揭发他人重大犯罪行为；提供侦破其他重大案件的重要线索；阻止他人重大犯罪活动；协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人（包括同案犯）；对国家和社会有其他重大贡献等表现。 此处的“重大犯罪”、“重大案件”、“重大犯罪嫌疑人”的标准，一般是指犯罪嫌疑人、被告人<u>可能判处无期徒刑以上刑罚</u>或者案件在<u>本省、自治区、直辖市或者全国范围内有较大影响</u>等情形。

报请核准 具体程序	犯罪嫌疑人自愿如实供述涉嫌犯罪的事实，有重大立功或者案件涉及国家重大利益，需要撤销案件的， <u>应当层报公安部，由公安部商请最高人民法院核准后撤销案件</u> 。报请撤销案件的公安机关应当同时 <u>将相关情况通报同级人民检察院</u> 。
--------------	---

- 问题 12：认罪认罚后，被告人反悔的处理。
- [法条索引]
《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第 53 条
- [答题话术]

当庭反悔 不认罪	[假如]问法院如何处理： 根据《指导意见》第 53 条规定，案件审理过程中，被告人反悔不再认罪认罚的， <u>人民法院应当根据审理查明的事实，依法作出裁判。需要转换程序的，依照本意见的相关规定处理。</u>
	[假如]问检察院如何处理： 检察院 <u>应当建议法院不再适用认罪认罚从宽制度，撤回从宽量刑建议，并建议法院在量刑时考虑相应情况</u> 。依法需要转为普通程序或者简易程序审理的，应当向法院提出建议。
裁判后 反悔上诉	[假如]问检察院如何处理： 认罪认罚案件，法院采纳检察院提出的量刑建议作出判决，被告人仅以量刑过重为由提出上诉，因被告人反悔不再认罪认罚 <u>致使从宽量刑明显不当的</u> ， <u>检察院可以依法提出抗诉</u> 。
	[假如]问法院如何处理： 认为原判决认定事实和适用 <u>法律正确、量刑适当的</u> ， <u>应当裁定驳回上诉，维持原判</u> ；认为原判决认定事实没有错误，但适用 <u>法律有错误或者量刑不当的</u> ， <u>应当依法改判</u> 。量刑改判时， <u>仍要遵守上诉不加刑原则</u> 。

- 问题 13：认罪认罚案件中的上诉问题。
- [对应场景 1] 有观点认为，在认罪认罚案件中，如果控辩双方达成一致意见后，被告人签署了认罪认罚具结书，法院也按照检察机关的确定刑量刑建议作出了判决，此时应当限制被告人的上诉权，原则上不应当允许被告人上诉。请对这一观点作出评价并给出理由。
- [法条索引] 《刑事诉讼法》第 227 条
- [答题话术]

该观点不正确。

(1) 根据我国《刑事诉讼法》的规定，上诉权是被告人的基本权利，应当予以充分保障。不得因被告人认罪认罚、签署具结书而剥夺其上诉权。

(2) 被告人反悔并上诉的理由多样，有的确实可能是在一审判决作出前后才发现或产生，不允许被告人上诉也有违刑事诉讼准确查明犯罪事实和尊重保障人权的任务。

(3) 目前我国认罪认罚从宽制度中仍然存在一些问题，尤其是在认罪认罚过程中被追诉者的知情权、法律帮助权和辩护权等尚未得到充分的保障，被追诉者尚难以对认罪认罚作出完全自愿且明智的决定，应当保留上诉这一权利救济的途径。

- [对应场景 2] 一审法院认定被告人认罪认罚，依法从轻处理后，被告人反悔上诉，认为其归案后自愿认罪认罚，原判量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。请问二审法院能否加刑？
- [法条索引] 《刑事诉讼法》第 227、237 条
- [答题话术]

只有被告人一方上诉的情况下，二审法院不得加重被告人的刑罚。首先，适用认罪认罚从宽程序的案件中，被告人的上诉权不能受限制。根据《刑事诉讼法》第 227 条规定，对被告人的上诉权，不得以任何借口加以剥夺。其次，根据《刑事诉讼法》第 237 条规定，第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受前款规定的限制。因此，根据上诉不加刑原则的规定，在只有被告人一方上诉的情况下，二审法院不得加重被告人的刑罚。

- [对应场景 3] 被告人不服一审判决提起上诉，检察机关认为被告人出尔反尔，不再符合认罪认罚条件，遂提出抗诉是否正确？
- [法条索引] 《刑事诉讼法》第 228 条
- [答题话术]

本案检察院抗诉不当。根据《刑事诉讼法》第 228 条规定，检察院抗诉必须具有法定的理由，即一审裁判确有错误。认罪认罚案件中，人民法院采纳检察院提出的量刑建议作出判决、裁定，被告人仅以量刑过重为由提出上诉，只有因被告人反悔不再认罪认罚致从宽量刑明显不当的，检察院才可以依法提出抗诉。可知，只有当检察院认为一审量刑明显不当时，方可抗诉。

- [对应场景 4] 如果检察院认为被告人以认罪认罚形式换取较轻刑罚，再利用上诉不加刑原则提出上诉，反映其认罪动机不纯；被告人上诉违背认罪认罚承诺，认罪认罚的从宽量刑幅度不应再适用，故应当加重处罚，才有利于维护适用认罪认罚从宽制度的司法效果。依法对被告人提起抗诉，二审法院能否加刑？
- [法条索引] 《刑事诉讼法》第 227、237 条
- [答题话术]

检察院提出抗诉后，案件确实不再属于“只有被告人一方上诉”的情形，因此不受上诉不加刑原则的绝对限制；但是，不受限制 ≠ 必然加刑。二审法院是否加刑，仍要以一审裁判是否确有错误、量刑是否明显不当为判断标准。二审法院要区分两种处理结果：

情形 1:	<u>原判量刑适当</u> ，抗诉理由不成立。如果二审法院经全面审查认为，原判量刑并无明显不当，那么即使检察院提出抗诉，也不能仅因被告人上诉就加重刑罚。此时，应当 <u>裁定驳回上诉、抗诉，维持原判</u> 。
情形 2:	原判从宽基础消失， <u>量刑明显不当</u> 。如果被告人一审认罪认罚获得较大从宽幅度，判后又仅以量刑过重为由上诉，二审经审查认为其已经反悔不再认罪认罚，导致原判从宽量刑明显失去基础， <u>量刑明显偏轻、罪责刑明显失衡，且检察院抗诉理由成立的，二审法院可以依法改判并加重刑罚</u> 。

- [对应场景 5] 适用速裁程序审理的认罪认罚案件，被告人能不能上诉，如果被告人不服一审判决上诉，二审法院应当如何处理？
- [前沿问题] 新版《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第 61 条
- [答题话术]

速裁程序被告人不服也可以上诉。第二审人民法院审查后，按照下列情形分别处理：

(1) 如果被告人以事实不清、证据不足为由上诉，且二审审查成立，应撤销原判，发回原审人民法院重新审理；

(2) 如果被告人仅以量刑不当为由上诉，原判量刑适当的，应驳回上诉、维持原判，原判适用法律错误或者量刑不当的，应依法改判；

(3) 如果被告人主张违背意愿认罪认罚，二审法院应审查认罪认罚的自愿性、真实性和合法性，确有强迫、引诱等情形的，应发回重审。

(4) 若只有被告人上诉，二审不得加重其刑罚；若检察院依法抗诉且抗诉理由成立，才可能突破上诉不加刑。

前沿热点：《监察法》

- 问题 14：结合监察法修改内容，本案监委在调查职务犯罪过程中有哪些违法情形？
- [法条索引] 《监察法》第 21、23、25、46 条
- [答题话术]

强制到案	(1) 监察机关根据案件情况，经依法审批，可以<u>强制涉嫌严重职务违法或者职务犯罪的被调查人到案接受调查</u>。 (2) 强制到案持续的时间<u>不得超过 12 小时</u>；需要采取管护或者留置措施的，强制到案持续的时间<u>不得超过 24 小时</u>。<u>不得以连续强制到案的方式变相拘禁被调查人</u>。
责令候查	对于存在四种情形的被调查人，可以采取<u>责令候查措施</u>。这四种情形分别是， (1) 不具有《监察法》第 24 条第 1 款所列情形的； (2) 符合留置条件，但患有严重疾病、生活不能自理的，系怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，或者生活不能自理的人的唯一扶养人； (3) 案件尚未办结，但留置期限届满或者对被留置人员不需要继续采取留置措施的； (4) 符合留置条件，但因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取责令候查措施更为适宜的。 <u>[记忆要点] 责令候查期间应当遵守的义务：市县、报告、及时到、不扰证人、不毁证。</u>
管护	1. 对于未被留置的下列人员，监察机关发现存在逃跑、自杀等重大安全风险的，经依法审批，<u>可以进行管护</u>： (1) 涉嫌严重职务违法或者职务犯罪的自动投案人员； (2) 在接受谈话、函询、询问过程中，交代涉嫌严重职务违法或者职务犯罪问题的人员； (3) 在接受讯问过程中，主动交代涉嫌重大职务犯罪问题的人员。采取管护措施后，应当立即将被管护人员送留置场所，<u>至迟不得超过 24 小时</u>。 2. 监察机关采取管护措施的，应当在 <u>7 日以内</u>依法作出留置或者解除管护的决定，特殊情况下可以<u>延长 1 日至 3 日</u>。

- 问题 15：《监察法》对留置时间的延长问题。
- [法条索引] 《监察法》第 48 条
- [答题话术]

3 个月	留置时间不得超过 3 个月。
+3 个月	在特殊情况下，可以延长一次， <u>延长时间不得超过 3 个月</u> 。 <u>省级以下监察机关采取留置措施的，延长留置时间应当报上一级监察机关批准</u> 。
+2 个月	<u>可能判处 10 年有期徒刑以上刑罚</u> ，监察机关依照前款规定延长期限届满，仍不能调查终结的， <u>经国家监察委员会批准或者决定</u> ，可以 <u>再延长 2 个月</u> 。
重新计算	省级以上监察机关在调查期间，发现涉嫌职务犯罪的被调查人另有与留置时的罪行不同种的 <u>重大职务犯罪或者同种的影响罪名认定、量刑档次的重大职务犯罪</u> ， <u>经国家监察委员会批准或者决定</u> ，自发现之日起依照本条第一款的规定重新计算留置时间。留置时间 <u>重新计算以一次为限</u> 。
<u>[记忆要点] 3+3+2+3+3</u>	

前沿热点：“审查逮捕”和“审查起诉”质效标准

➤ 问题 16：逮捕的条件。

- [对应场景 1]张三涉嫌多次诈骗，现有证据已证明其中一次诈骗系张三实施，相关证据已经查证属实，根据已经查明的事实、情节，可能判处有期徒刑三年。另有证据证明张三企图逃跑，采取取保候审不足以防止社会危险性。检察院以“部分犯罪事实尚未查清，全案未达到起诉标准”为由不批准逮捕。该处理是否正确？

- [法条索引]《刑事诉讼法》第 81 条；《人民检察院刑事诉讼规则》第 128 条

- [答题话术]

亮出结论	本案不批准逮捕的处理 <u>不正确</u> 。审查逮捕应当适用逮捕标准，不能仅因部分犯罪事实尚未查清为由，对已经符合逮捕条件的犯罪嫌疑人作出不捕决定。
逮捕条件	一般逮捕应当同时具备 3 个条件： <u>有证据证明有犯罪事实；可能判处徒刑以上刑罚；采取取保候审尚不足以防止发生社会危险性。</u>
证据标准	“有证据证明有犯罪事实”，要求同时具备：①有证据证明 <u>发生了犯罪事实</u> ；②有证据证明该犯罪 <u>事实是犯罪嫌疑人实施的</u> ；③证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据 <u>已经查证属实</u> 。这里的犯罪事实，可以是数个犯罪行为中的任何一个，也可以是多次犯罪中的一次，并非必须查清全部犯罪事实。
本案处理	本案已经符合逮捕条件，应当依法批准逮捕。对 <u>尚需补充的证据，应当在作出批准逮捕决定的同时，制发继续侦查提纲，并跟踪督促，而不是以全案尚未达到证据确实、充分为由不捕。</u>

[延申考点]

径行逮捕	对有证据证明有犯罪事实，可能判处十年有期徒刑以上刑罚的，或者有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚，曾经故意犯罪或者身份不明的，应当予以逮捕。 <u>[记忆要点]径行逮捕条件：有证据、够十年；有证据、够徒刑、曾故意或身份疑；</u>
转化逮捕	被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反取保候审、监视居住规定，情节严重的，可以予以逮捕。

- [对应场景 2]李四涉嫌盗窃，现有证据仅有李四本人的有罪供述，没有其他证据印证。

检察院认为李四系初犯，且认罪悔罪，以“不致发生社会危险性”为由作出不批准逮捕决定。该理由是否正确？

- [前沿问题]《人民检察院审查逮捕质效标准（试行）》第 25、27、30—32 条。

- [答题话术]

亮出结论	本案不批准逮捕的决定 <u>本身正确</u> ，但不捕 <u>理由错误</u> 。
说明理由	人民检察院应当 <u>准确适用不捕情形</u> 。对不构成犯罪的犯罪嫌疑人，不能以证据不足作出不捕决定或者以不致发生社会危险性作出不捕决定；对证据不足的犯罪嫌疑人，不能以不致发生社会危险性作出不捕决定。 本案仅有犯罪嫌疑人本人的有罪供述，没有其他证据印证，不属于“有证据证明有犯罪事实”， <u>应当以证据不足为由不捕，不能以“不致发生社会危险性”为由不捕</u> 。对因证据不足作出不批准逮捕决定，需要补充侦查的，应当督促公安机关补充侦查取证或者依法作出处理。

➤ 问题 17：提起公诉的条件。

- [对应场景]张三与李四涉嫌共同盗窃，张三已经到案，李四在逃。关于张三实施盗窃的定罪量刑事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任，但部分赃物去向无法查明。此外，张三另涉嫌一宗诈骗，经过依法补充侦查仍无法查清。检察院认为“同案犯尚未到案、全案事实尚未查清”，拟对张三全案作出证据不足不起诉决定。该处理

是否正确？

- [法条索引]《高检规则》第 355 条；《刑事诉讼法》第 55 条
- [答题话术]

亮出结论	该处理 <u>不正确</u> 。
起诉条件	对于犯罪嫌疑人的 <u>犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的</u> ，应当作出起诉决定。
“事实清楚”	具有下列情形之一的，可以认为犯罪事实已经查清： （一）属于单一罪行的案件， <u>查清的事实足以定罪量刑或者与定罪量刑有关的事实已经查清，不影响定罪量刑的事实无法查清的</u> ； （二）属于数个罪行的案件， <u>部分罪行已经查清并符合起诉条件，其他罪行无法查清的</u> ； （三）无法查清作案工具、赃物去向，但 <u>有其他证据足以对被告人定罪量刑的</u> ； （四）证人证言、犯罪嫌疑人供述和辩解、被害人陈述的内容 <u>主要情节一致，个别情节不一致，但不影响定罪的</u> 。 对于符合前款第二项情形的， <u>应当以已经查清的罪行起诉</u> 。
证明标准	“证据确实、充分”，应当同时符合： <u>①定罪量刑的事实都有证据证明；②据以定案的证据均经法定程序查证属实；③综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑</u> 。
本案处理	本案盗窃罪行已经符合起诉条件， <u>应当以已经查清的盗窃罪行提起公诉，不能因同案犯在逃、部分赃物去向不明或者另案罪行无法查清，就对张三全案作出证据不足不起诉决定</u> 。

- [命题分析]“事实清楚”不等于所有细节都查清；“罪名有争议”不等于证据不足；“其他罪行不清”不妨碍对已查清且符合起诉条件的罪行起诉。

➤ 问题 18：不起诉种类。

- [对应场景]王五涉嫌盗窃，经两次退回补充侦查，认定其实施盗窃的关键证据之间仍存在无法排除的矛盾，不能排除他人作案的合理可能。检察院考虑王五曾作有罪供述，并已赔偿被害人损失，拟以“犯罪情节轻微”为由作出酌定不起诉决定。该处理是否正确？应当如何区分不同类型的不起诉？

➤ [答题话术]

答题话术	本案不起诉 <u>类型适用错误</u> ，应当依法作出 <u>证据不足（存疑）不起诉决定</u> ，而非酌定不起诉决定。本案现有证据不能排除合理怀疑，尚不能确定王五构成犯罪，不能因为其曾认罪、已经赔偿，就将“证据不足”作为“犯罪情节轻微”处理。	
延申考点	法定不诉	对于 <u>没有犯罪事实，或者具有法定不应当追究刑事责任情形</u> 的，应当依照《刑事诉讼法》第 177 条第 1 款作出不起诉决定。
	存疑不诉	对于 <u>证据不足，不能确定犯罪嫌疑人构成犯罪和需要追究刑事责任</u> ，不符合起诉条件的，应当依法作出证据不足不起诉决定。
	酌定不诉	① <u>犯罪情节轻微</u> ；②依照刑法规定 <u>不需要判处刑罚或者免除刑罚</u> 。 [命题分析]认罪悔罪、退赃退赔、赔偿谅解、初犯偶犯等，是综合判断的考虑情节，不能代替上述两个法定条件，更不能代替对犯罪事实和证据的审查。
	附条件不诉	[记忆要点]小孩犯罪、456、一年以下、够起诉、悔过、可以附条件。 [命题分析]对于犯罪情节轻微，已经符合酌定不起诉条件的 <u>未成年犯罪嫌疑人，应当直接适用酌定不起诉，不能作出附条件不起诉决定</u> 。不能对本应直接不起诉的未成年人，再附加考验条件

专题二：理论热点话术储备

➤ 问题 19：结合本案，谈谈你对审判为中心的诉讼制度改革的认识。

➤ [法条索引] “两高三部”《关于推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的意见》

何为审判为中心？	以审判为中心也就是我们常说的“ <u>审判中心主义</u> ”，是指在刑事诉讼的各个阶段关系中，都凸显审判的 <u>中心地位</u> ，将刑事审判作为整个 <u>诉讼的核心</u> 。
为何要坚持审判为中心？	侦查阶段和起诉阶段均是刑事审判的预备阶段， <u>只有审判才具有定纷止争的权威性、终局性作用</u> 。在整个刑事诉讼过程中，只有在审判阶段才能 <u>决定被追诉人是否有刑事责任以及责任的大小</u> 。审判是司法活动的核心环节，是所有社会矛盾解决的终极手段，是社会公正的 <u>最后一道“防线”</u> 。
怎样做到审判为中心？	以审判为中心的刑事诉讼制度改革”的理论基础是审判中心主义理论。包括以下几个方面的含义： (1) <u>实现庭审的实质化</u> 。要实现审判中心主义，首先要实现以庭审为中心，改变庭审虚置化、形式化的倾向，使庭审真正成为事实查明、证据认定、适用法律的核心，发挥庭审的把关作用，使法庭审理的案件经得起法律的考验和历史的考验，实现法律效果和社会效果的统一。 (2) <u>实现审判程序对审前程序的制约</u> 。充分发挥审判程序的诉讼制约功能，使侦查程序、审查起诉程序都围绕审判程序展开和进行；充分发挥审判保障诉权、尊重人权的功能，建立健全刑事诉讼中的司法审查机制。 (3) <u>实现依法独立公正行使审判权</u> 。审判中心主义就是要求依法独立行使审判权，实现“由审理者裁决，由裁决者负责”的审判权运行机制，坚持“无罪推定原则”“证据裁判原则”“疑罪从无原则”，严格“排除非法证据”，完善“证人出庭制度”“当庭宣判制度”等，使审判真正担负起实现司法公正的重任。
别忘了结合本案	结合本案..... 非法证据排除、严格把握定罪标准、疑罪从无、直接言词、完善证人出庭.....
最后口号升华	总之，推动以审判为中心的刑事诉讼制度改革，就是要坚持审判中心主义，发挥审判维护司法公正、引领社会公平正义的作用，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

➤ 问题 20：结合本案，请你谈谈对量刑规范化改革的认识。

➤ [法条索引] “两高三部”《关于规范量刑程序若干问题的意见》

what	“量刑规范化”是指对于同一地区同一时期、案情相似的案件，所判处的 <u>刑罚应当基本均衡</u> 。
why	现行刑罚制度比较粗放、法定刑幅度较大、裁量空间比较大的情况下， <u>规范法官的自由裁量权</u> ，让法官的量刑越来越公正和精细，增强量刑的公开性， <u>实现量刑公正</u> ，杜绝“同罪不同罚”，实现该宽则宽，当严则严，宽严相济，罚当其罪，确保裁判法律效果和社会效果的统一。
how	(1) 引入 <u>量刑建议</u> ； (2) 将量刑纳入法庭审理程序， <u>建立和完善相对独立的量刑程序</u> ； (3) 要求审判法官 <u>应当听取控辩双方以及其他当事人提出的量刑建议或意见</u> ，保障被告人能够获得充分的量刑辩护权，保障被害人参与量刑活动，允许有关方面提交反映被告人行为危害性和人身危险性的社会调查报告； (4) 要求人民法院的 <u>裁判文书中应当说明量刑理由</u> ；

➤ 问题 21：结合案情，本案被二审法院改判或发回重审，审理本案的法官是否要追责？

谈谈完善司法责任制对于促进司法公正的意义。

➤ [法条索引] 《最高人民法院关于进一步加强合议庭职责的若干规定》第 10 条

➤ [答题话术]

基本内容	司法责任制主要包括几个方面： <u>一是职权配置，即由审理者裁判；二是责任承担，既然把权力给审理者了，最后当然也要由裁判者负责。三是发生错案，要启动追责程序。</u>
重大意义	推行司法责任制，意味着 <u>司法机关办案权力重心下移</u> 。过去司法机关办案，内部层层审批，终极性话语权在领导层；现在下移至主审法官、合议庭、主任检察官，遵循“谁办案、谁决定、谁负责”的原则， <u>有助于建立权责明晰、权责统一的司法权力运行机制。通过司法责任制改革，法院、检察院的优秀人才集中到办案一线；法官、检察官独立对案件作出处理决定，增强了法官、检察官的责任感；案件服判息诉率明显提升，司法公信力得到明显提高。</u>
喊出口号	总之，如果说建立公正高效权威文明的社会主义司法制度是司法体制改革的终极目标， <u>提高司法公信力是司法体制改革的近期目标或阶段性目标</u> ，那么，建立和完善司法责任制则是实现司法体制改革目标的必由之路。

➤ 问题 22：结合案情，请阐明非法证据排除规则的诉讼价值。

➤ [法条索引] 《办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》

➤ [答题话术] 非法证据排除规则的诉讼价值主要体现在以下三个方面：

保障人权	第一，非法证据排除规则 <u>有利于保障犯罪嫌疑人、被告人的人权乃至每个公民的合法权益不受侵犯</u> 。非法证据排除规则对刑讯逼供等非法取证行为进行否定性评价，消除非法取证的心理动力，从而达到保障诉讼参与人各项权利、保障无辜的人不受追究的目的。
程序正义	第二，非法证据排除规则 <u>有利于保障程序公正，保障诉讼程序独立价值的实现</u> 。非法证据排除规则有助于督促公检法机关严格遵守刑事诉讼法的规定，通过程序性制裁来实现对程序公正的追求。
规范司法	第三，非法证据排除规则 <u>有利于规范司法行为，维护司法权威，彰显法治精神</u> 。司法机关若非法取证、带头违法，就会严重损害司法机关形象，损害法律权威，对整个社会的法律信仰和法治精神也有着巨大的破坏。

➤ 问题 23：结合我国的立法规定，谈谈非法证据排除规则是如何平衡实体公正与程序公正的关系？

➤ [法条索引] 《办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》1-7 条；《刑诉解释》第 123-126 条

➤ [答题话术]

- 非法证据排除规则在刑事诉讼中的确立，是立法者对实体公正和程序公正价值权衡的结果。
- 如果允许将非法取得的证据作为定案根据，对查明案情、实现国家的刑罚权是有帮助的，但这样做又是以侵犯宪法保障的公民基本权利、违反程序公正为代价的；反之，如果将非法取得的证据一律排除，虽然体现了程序的正义，但可能会影响到对案件真相的查明和犯罪的惩治。因此，从程序正义的理念考虑，我国刑诉法明确规定，采用暴力、威胁以及限制人身自由等非法手段获取的供述、证人证言、被害人陈述不能作为定案依据，但是，考虑到实体正义的价值需要，针对实物证据，不符合法定程序，可能严重影响司法公正的，又给了办案人员予以补正或作出合理解释的机会。
- 为了实现实体正义和程序正义之间的平衡，应当赋予法官对于非法获得的实物证据是否采用一定的裁量权。从近现代刑事诉讼制度的发展趋势来看，程序正义的理念愈来愈受到重视，当实体真实与程序正义发生冲突时，各国越来越倾向于优先考虑程序正义。

➤ 问题 24：谈谈缺席审判程序如何平衡惩罚犯罪和保障人权的理念

➤ [法条索引] 《刑事诉讼法》第 291-297 条

➤ [答题话术]

惩罚犯罪	一方面，刑事缺席审判制度 <u>体现了刑事诉讼惩罚犯罪的基本理念</u> 。建立刑事缺席审判制度有
------	---

	利于及时对犯罪嫌疑人、被告人的人身刑进行判处。
保障人权	另一方面，建立刑事缺席审判制度必须坚持<u>惩罚腐败犯罪与保障被告人人权相平衡的原则</u>。对被告人而言，出席庭审是其一项重要的诉讼权利。一旦缺席审判，被告人将无法行使相关权利。刑事诉讼法具体通过以下制度来落实对被告人的人权保障： (1) <u>保障被告人的知情权</u>。人民法院通过有关国家条约规定的或者外交途径提出的司法协助方式，或者被告人所在地法律允许的其他方式，将传票和人民检察院的起诉书副本送达被告人。 (2) <u>对刑事缺席审判的案件实行强制法律援助辩护制度</u>。根据刑事诉讼法第 293 条的规定，对于缺席审判的案件，被告人及其近亲属没有委托辩护人的，人民法院应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。 (3) <u>保障近亲属的参诉权</u>。根据《刑诉解释》第 603 条规定，被告人的近亲属参加诉讼的，可以发表意见，出示证据，申请法庭通知证人、鉴定人等出庭，进行辩论。 (4) <u>赋予了被告人及其近亲属独立的上诉权</u>。刑事诉讼法第 294 条第 1 款规定：“人民法院应当将判决书送达被告人及其近亲属、辩护人。被告人或者其近亲属不服判决的，有权向上一级人民法院上诉。辩护人经被告人或者其近亲属同意，可以提出上诉。” (5) <u>赋予了被告人异议权</u>。刑事诉讼法第 295 条第 2 款明确规定：“罪犯在判决、裁定发生法律效力后到案的，人民法院应当将罪犯交付执行刑罚。交付执行刑罚前，人民法院应当告知罪犯有权对判决、裁定提出异议。罪犯对判决、裁定提出异议的，人民法院应当重新审理。

专题三：证据与证明

- 问题 25：从证据的“三性”分析××证据是否具有可采性。
- [法条索引]《刑诉解释》第 139 条
- [答题话术]

客观性	证据的客观性，是指证据必须是客观存在的事实，不以人的主观意志为转移。 [命题分析]任何主观想象、虚构、猜测、假设、臆断、梦境以及来源不清的道听途说等并非客观存在的材料，都不能成为刑事诉讼中的证据。
关联性	关联性也称为相关性，是指证据必须与案件事实有客观联系，对证明刑事案件事实具有某种实际意义；反之，与本案无关的事实或材料，都不能成为刑事证据。 [命题分析]类似事件、品格事实、表情、被害人过去的行为与是否犯罪不具关联性。
合法性	是指对证据必须依法加以收集和运用。 [命题分析]证据合法性需要满足以下条件：（1）证据的收集和运用<u>主体要合法</u>。（2）证据的形式应当合法。（3）证据的提供、收集和审查，必须<u>符合法定的程序要求</u>。（4）证据必须经法定程序出示和查证。

- 问题 26：证据的“三大”原则之简述证据裁判原则的含义。从证据裁判原则角度判断对被告人能否定罪。
- [法条索引]《刑事诉讼法》第 55 条
- [答题话术]

基本概念	证据裁判原则，又称证据裁判主义，其基本含义是指 <u>对于诉讼中事实的认定，应依据有关的证据作出；没有证据，不得认定事实</u> 。
具体含义	在现代诉讼制度下，证据裁判原则至少包含有以下几个方面的含义： (1) 对事实问题的裁判<u>必须依靠证据</u>，没有证据不得认定事实。 (2) 裁判所依据的必须是<u>具有证据资格</u>的证据。 (3) 裁判所依据的必须是<u>经过法庭调查</u>的证据，除非法律另有规定。

(4) 综合全案证据必须达到法定的定罪标准才能认定案件事实。

[记忆要点] 靠证据、具资格、经查证、够标准。

➤ 问题 27：本案的 XXX 属于何种法定证据种类。

➤ [法条索引] 《刑事诉讼法》第 50 条、《刑诉解释》第 100、101 条

➤ [答题话术]

1. 物证	以其外部特征、存在场所和物质属性证明案件事实的实物和痕迹。
2. 书证	以记载内容和表达的思想来证明案件事实的书面文件和其他物品。 [命题分析] 书证 3 要件：(1) 内容有关；(2) 物质载体；(3) 诉讼外形成。
3. 证人证言	证人就其所感知的案件情况向公安司法机关所作的陈述。
4. 被害人陈述	被害人就其受害情况和其他与案件有关的情况向公安司法机关所作的陈述。
5. 供述、辩解	犯罪嫌疑人、被告人就与案件有关的事实情况向公安司法机关作的陈述。 [命题分析] 同案犯之间的揭发，如果是共犯内的事实揭发属于口供，共犯外的事实揭发属于证人证言。
6. 鉴定意见	受指派或聘请的鉴定人，对案件中专门性问题鉴定后所作出的书面意见。
7. 勘验、检查、辨认、侦查实验笔录	是指办案人员在勘验、检查、辨认、侦查实验活动中所作的记录。
8. 视听资料、电子数据	(1) 视听资料是指以录音、录像、计算机磁盘所记载的音像信息来证明案件真实情况的资料。 [命题分析] 讯问时的同步录像，记录犯罪嫌疑人交代自己犯罪经过的内容，属于口供，但如果用其证明刑讯逼供是否发生时，属于视听资料。 (2) 电子数据是指在案件发生过程中形成的，以数字化形式存储、处理、传输的，能够证明案件事实的数据。 [命题分析] 判断电子数据三要件：(1) 内容有关；(2) 数字化载体；(3) 诉讼外形成。
9. 专门性问题报告	因无鉴定机构，或根据法律规定，指派、聘请有专门知识的人就案件的专门性问题出具的报告，可以作为证据使用。（《刑诉解释》第 100 条）
10. 事故调查报告	有关部门对事故进行调查形成的报告，在刑事诉讼中可以作为证据使用。（《刑诉解释》第 101 条）

➤ 问题 28：本案的各类证据中，哪些不能作为定案依据？

➤ [法条索引] 《刑诉解释》第 4 章第 2 节-第 8 节

➤ [答题话术]

物证、书证	[法条索引] 《刑诉解释》第 83、84、86 条 物证、书证不能作为定案依据的情形：“真伪不明”“来源不明”“无法解释”。
证人证言、被害人陈述	[法条索引] 《刑诉解释》第 88、89、125、91 条 证人证言、被害人陈述不能作为定案依据的情形：“麻醉”“猜测”“未个别”“核对”“翻译”“暴限胁”“拒绝出庭不真实”。
供述	[法条索引] 《刑诉解释》第 94、123 条；《冤假错案工作机制意见》第 8 条 供述不能作为定案依据的情形：“核对”“翻译”“无法代”“场外”“音、像”“暴、限、胁”。
鉴定意见	[法条索引] 《刑诉解释》第 98、99 条 鉴定意见不能作为定案依据的情形可概括为：“见错就排”。
勘验、检查、侦	[法条索引] 《刑诉解释》第 103、107 条

查实验笔录	1. 勘验、检查笔录不能作为定案依据的情形：“ <u>无法解释</u> ”。 2. 侦查实验笔录不能作为定案依据的情形可概括为：“ <u>条件差异</u> ”。
辨认笔录	[法条索引]《刑诉解释》第 105 条 辨认笔录不能作为定案依据的情形：“ <u>没有侦查人员主持；指示预见个混混。</u> ”
视听资料、电子数据	[法条索引]《刑诉解释》第 109、114 条 视听资料、电子数据不能作为定案依据的情形：“ <u>真伪不明、无法解释</u> ”。
专门性问题的报告	[法条索引]《刑诉解释》第 100 条 参照鉴定意见规则。

- 问题 29：法院发现检察院未移送案发现场的监控录像以及讯问时的同步录音录像分别该如何处理？
- [法条索引]《刑诉解释》第 73、74 条
- [答题话术]

1. 证据材料未移送的处理	根据《刑诉解释》第 73 条， <u>未随案移送的，法院应当通知检察院在指定时间内移送。</u> 仍未移送的，法院应当根据在案证据对案件事实作出认定。
2. 讯问过程录音录像未移送的处理	根据《刑诉解释》第 74 条，相关讯问过程的录音录像未随案移送的， <u>必要时，法院可以通知</u> 检察院在指定时间内移送。未移送， <u>导致不能排除非法方法收集证据情形的，对有关证据应当依法排除；导致有关证据的真实性无法确认的，不得作为定案的根据。</u>

- 问题 30：行政机关或监察机关收集的各类证据能否在刑事诉讼中作为证据使用问题。
- [法条索引]《刑诉解释》第 75、76 条
- [答题话术]

1. 行政执法办案中收集的证据	行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的 <u>物证、书证、视听资料、电子数据</u> 等证据材料，经法庭查证属实，且收集程序符合有关法律、行政法规规定的， <u>可以作为定案的根据。</u>
2. 监委调查中收集的证据	监察机关依法收集的 <u>证据材料</u> ， <u>在刑事诉讼中可以作为证据使用。</u> 对前款规定证据的审查判断， <u>适用刑事审判关于证据的要求和标准。</u>

- 问题 31：来自境外的证据材料能否作为定案依据？
- [法条索引]《刑诉解释》第 77 条
- [答题话术]

机关移送	1. 对来自境外的证据材料，人民检察院应当随案移送有关材料来源、提供人、提取人、提取时间等情况的说明。 2. 经人民法院审查，相关证据材料能够证明案件事实且符合刑事诉讼法规定的，可以作为证据使用，但提供人或者我国与有关国家签订的双边条约对材料的使用范围有明确限制的除外； <u>材料来源不明或者真实性无法确认的，不得作为定案的根据。</u> [命题分析]对来自境外的证据审查，也需要满足证据的“三性”。
个人提供	当事人及其辩护人、诉讼代理人提供来自境外的证据材料的，该证据材料应当经所在国公证机关证明，所在国中央外交主管机关或者其授权机关认证，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续，但我国与该国有互免认证协定的除外。（2 认证+1 证明）

➤ 问题 32：证据的理论分类的判断

➤ [答题话术]

原始证据	凡来自原始出处，即直接来源于案件事实的“第一手”证据材料。
传来证据	凡不是直接来源于案件事实，而是经过转述、复制获得的证据材料。
[命题分析]通常情况下原始证据的证明价值大于传来证据。	
直接证据	可以单独、直接证明案件主要事实的证据。直接证据可以分为肯定性直接证据和否定性直接证据。
间接证据	不能单独、直接证明刑事案件主要事实，需与其他证据相结合才能证明的证据。
[命题分析]虽然直接证据能够单独地、直接地证明案件主要事实，但在直接证据的运用中应当坚持孤证不能定案的原则。	

➤ 问题 33：如果没有直接证据，如何运用间接证据证明案件事实？

➤ [法条索引]《刑诉解释》第 140 条

➤ [答题话术]

如果没有直接证据，但间接证据同时符合下列条件的，可以认定被告人有罪：

- (1) 证据已经查证属实；
- (2) 证据之间相互印证，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问；
- (3) 全案证据形成完整的证据链；
- (4) 根据证据认定案件事实足以排除合理怀疑，结论具有唯一性；
- (5) 运用证据进行的推理符合逻辑和经验。

➤ 问题 34：熟悉“七大”证据规则

➤ [答题话术]

1. 关联性规则	指只有与案件事实有关的材料，才能作为证据使用。没有关联性的证据不具有可采性，但具有关联性的证据未必都具有可采性。 [命题分析]品格证据、类似行为、特定的诉讼行为，被害人过去行为与是否犯罪不具关联性。
2. 非法证据排除规则	指违反法定程序，以非法方法获取的证据，原则上不能为法庭采纳。 [命题分析]该原则为命题重点，具体排除的情形，参见问题 37-42。
3. 自白任意性规则	指在刑诉中，只有基于被追诉人自由意志而做出的自白（有罪供述），才具有可采性。违背当事人意愿或违反法定程序而强制作出的供述不是自白，而是逼供，不具有可采性，须予以排除。
4. 传闻证据规则	又称为传闻证据排除规则，是指法律排除传闻证据作为认定犯罪事实根据的规则。根据这一规则，如无法定理由，证人在庭审期间以外及庭审准备期间以外的陈述，不得作为认定被告人有罪的证据。
5. 意见证据规则	指证人只能陈述自己亲身感受的事实，不得陈述对案件事实的意见或者结论。 [命题分析]鉴定人并不受该规则约束。
6. 补强证据规则	在运用某些证明力显然薄弱的证据认定案情时，必须有其他证据补强其证明力，才能被法庭采信为定案依据。
7. 最佳证据规则	又称原始证据规则，是指以文字、符号、图像等方式记载的内容来证明案情时，其原件才是最佳的证据。

➤ 问题 35：简述传闻证据规则，判断案例中××证据是否为传闻证据，根据我国法律规定，证人在庭外的证言（传闻证据）能否作为定案的依据。

- [法条索引] 《刑事诉讼法》第 195 条
- [答题话术]

传闻证据规则	是指法律 <u>排除</u> 传闻证据作为认定事实根据的规则。
何为传闻证据	指“ <u>亲历者</u> ”在 <u>本案法庭审理之外</u> 作出的用来证明其本身所主张的事实的各种 <u>陈述</u> 。主要包括两种形式： <u>一是书面传闻证据</u> ，即亲身感受了案件事实的证人在庭审期日之外所作的书面证人证言； <u>二是言词传闻证据</u> ，即证人并非就自己亲身感知的事实作证，而是向法庭转述他从别人那里听到的情况。
我国立法现状	<u>我国立法没有明确规定</u> 传闻证据排除规则，即证人在庭外的证言，如果能够查证属实仍可以作为定案的依据。

- 问题 36：简述补强证据规则，案例中哪些证据证明力薄弱需要其他证据予以印证（补强）？××证据能否作为补强证据。
- [法条索引] 《刑诉解释》第 143 条
- [答题话术]

补强证据规则	在运用某些证明力显然薄弱的证据认定案情时， <u>必须有其他证据补强</u> 其证明力，才能被法庭采信为定案依据。
需补强的证据	下列证据有其他证据 <u>印证</u> ，可以采信： (1) 生理上、精神上有缺陷对案件事实的认知和表达存在一定困难，但尚未丧失正确认知、表达能力的被害人、证人和被告人所作的陈述、证言和供述； (2) 与被告人有亲属关系或者其他密切关系的证人所作的有利于被告人的证言，或者与被告人有利害冲突的证人所作的不利于被告人的证言。
补强证据条件	(1) <u>具有证据能力</u> ；(2) <u>具有担保补强对象真实的能力</u> ；(3) <u>具有独立的来源</u> 。

- 问题 37：结合案情，本案哪些非法证据不能作为定案依据。
- [法条索引] 《排非规定》第 1-7 条 《刑诉解释》第 123-126 条 《排非规程》第 1-3 条
- [答题话术]

言词证据 (绝对排)	1. 采用暴力、威胁以及非法限制人身自由等非法方法收集的<u>证人证言、被害人陈述</u>，应当予以排除。 2. 采用下列非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人<u>供述</u>，应当予以排除： (1) 采用殴打、违法使用戒具等暴力方法或者变相肉刑的恶劣手段，使犯罪嫌疑人、被告人遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出的供述； (2) 采用以暴力或者严重损害本人及其近亲属合法权益等进行<u>威胁</u>的方法，使犯罪嫌疑人、被告人遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出的供述； (3) 采用非法拘禁等非法限制人身自由的方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述。 3. 采用刑讯逼供方法使被告人作出供述，之后被告人受该刑讯逼供行为影响而作出的与该供述相同的<u>重复性供述</u>，应当一并排除。除非更换调查、侦查人员，其他调查、侦查人员再次讯问时告知有关权利和认罪的法律后果，被告人自愿供述的或者审查逮捕、审查起诉和审判期间，<u>检察人员、审判人员讯问时告知诉讼权利和认罪的法律后果</u>，被告人自愿供述的。 [记忆要点]言词排非“暴”“限”“胁”，重复供述一并排，除非换人换阶段。
实物证据 (相对排)	本案收集物证、书证不符合法定程序，可能严重影响司法公正的，应当予以<u>补正或者作出合理解释</u>；不能补正或者作出合理解释的，对该证据应当予以排除。 [记忆要点]非法实物相对排，补正解释方可采。

- 问题 38：侦查阶段重大刑事案件讯问合法性的核查程序与非法证据排除程序。
- [法条索引]《排非规程》第 4-5 条
- [答题话术]

案件类型	可能判处无期徒刑、死刑的案件 或其他重大案件。
时间节点	侦查终结前。（确保在移送审查起诉前完成合法性审查）
责任主体	1. 侦查机关：应当书面通知检察院驻看守所检察人员启动核查。 2. 检察人员：应当在侦查终结前询问犯罪嫌疑人，核查是否存在刑讯逼供等非法取证情形，并对核查过程全程同步录音录像。
核查意见书	应当制作重大案件讯问合法性核查意见书，送达侦查机关。
通知排非	1. 经核查确有或不能排除非法取证情形的，应当通知侦查机关依法排除非法证据。 2. 侦查机关对非法取证情形没有异议，或经复查认定确有非法取证情形的，应当及时依法排除非法证据。
排非后果	1. 不得作为提请批准逮捕、移送审查起诉的根据，并制作排除非法证据结果告知书，将排除非法证据的情况依法告知人民检察院。 2. 重大案件讯问合法性核查意见书和被排除的非法证据应当随案移送，并写明为依法排除的非法证据。
[记忆要点]死无重大必核查，驻所检察来把关；侦查终结前完成，同步录像不可缺；核查意见书面达，非法证据通知排；随案移送须标注，程序违法后果严。	

- 问题 39：审判阶段排除非法证据的相关程序
- [法条索引]《排非规程》第 8-34 条
- [答题话术]

告知义务	法院送达起诉书副本时，应告知其有权申请排非并同时提供相关线索或材料。
申请时间	应当在开庭审理前提出申请，但在庭审期间发现线索或材料等情形除外。
申请方式	应当提交书面申请。书写确有困难的，可以口头，但应记录在案，并签名或捺指印。
申请条件	应当提供相关线索或者材料。未提供相关线索或材料的，法院应当告知其补充提交。未补充的，法院对申请不予受理，并在开庭审理前告知被告人及其辩护人。
申请效果	申请排非且提供相关线索或者材料的，法院应当召开庭前会议。
权利保障	1. 申请排非，但没有辩护人的，法院应当通知法律援助机构指派律师为其辩护。 2. 申请排除非法证据的，法院应当通知被告人参加庭前会议。
庭前会议	开庭前，法院不能直接做出排除非法证据的决定，只是召开庭前会议，听取意见，了解情况。法院对证据收集的合法性有疑问的，应当在庭审中进行调查；对证据收集的合法性没有疑问，且没有新的线索或者材料表明可能存在非法取证的，可以不再决定进行调查并说明理由。
启动调查	合法性有疑问，应当进行调查。
调查时间	原则上应当先行当庭调查。对于被申请排除的证据和其他犯罪事实没有关联等情形，为防止庭审过分迟延，可以先调查其他犯罪事实，再对证据收集的合法性进行调查。在对证据收集合法性的法庭调查程序结束前，不得对有关证据出示、质证。
调查步骤	1. 宣布庭前会议中对证据收集合法性的审查情况及双方的争议焦点； 2. 辩方说明排除非法证据的申请及相关线索或者材料； 3. 公诉人出示证明证据收集合法性的证据材料，辩方可以对相关证据进行质证，经审判长准许，公诉人、辩护人可以向出庭的侦查人员或者其他人员发问； 4. 控辩双方对证据收集的合法性进行辩论。
排除情形	确认存在或不能排除存在以非法方法收集证据的。

排除效果	排除的证据，不得宣读、质证， <u>不得作为判决的根据</u> 。排除非法证据后，事实清楚，证据确实、充分，能认定有罪的，作有罪判决；证据不足，不能认定有罪的，作无罪判决；部分事实清楚，证据确实、充分的，依法认定该部分事实。
裁判文书	审查、调查结论，应当在裁判文书中写明，并说明理由。

➤ 问题 40：庭审阶段法院在调查证据合法性时，如何分配举证责任？

➤ [法条索引] 《刑诉法》第 58-60 条

➤ [答题话术]

初步证明	当事人及其辩护人申请法院排除非法证据的， <u>应当提供相关线索或者材料</u> ，这种证明标准只需达到“合法性有疑问”的程度即可。
举证责任	检察院应当对证据收集的合法性 <u>承担举证责任</u> ，这种证明标准需要达到 <u>确实、充分</u> 的标准，否则，该证据不得作为定案依据。

➤ 问题 41：二审阶段对证据合法性的审查程序和裁判结果。

➤ [法条索引] 《排非规程》第 30-34 条

➤ [答题话术]

审查情形	二审应当对证据合法性进行审查的情形： (1) 一审法院未告知被告人申请排非的权利，二审才提出申请的； (2) 对一审法院有关证据收集合法性的调查结论有异议， <u>上诉、抗诉</u> 的； (3) 一审 <u>庭审后</u> 才发现涉嫌非法取证线索、材料的，二审才提出申请的。 [记忆要点]一审未告知申请，一审审查我不服，一审之后才发现。
审理结果	(1) 一审法院对排非申请未予审查，并以该证据作为定案根据，可能影响公正审判的，二审法院应当裁定撤销原判，发回重审。 (2) 一审法院对依法应当排除的非法证据未予排除的，二审法院可以依法排除非法证据。排除非法证据后， <u>根据不同情形对案件依法作出处理</u> 。 [记忆要点]一审未查“应”发回，一审未排“可”排除。

➤ 问题 42：举证责任的分配。如果辩护人坚持做无罪辩护，对其无罪辩护主张是否承担证明责任？

➤ [法条索引] 《刑事诉讼法》第 51 条

➤ [答题话术]

基本含义	举证责任是指人民检察院或某些当事人对其在诉讼中的主张应当承担的收集或提供证据予以证明的责任，否则，将承担其主张不能成立的后果。
分配方式	根据《刑事诉讼法》第 51 条规定， <u>公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担</u> 。辩护人作无罪辩护，对其消极的诉讼主张不承担证明责任，但其享有证明被告人无罪的权利。本案如果被告人有罪无罪真伪不明，则应当由承担证明责任的检察院承担败诉风险。

➤ 问题 43：各个诉讼阶段的证明标准，如果案件未达证据标准该如何处理？

➤ [法条索引] 《刑事诉讼法》第 112、55 条；《高检规则》第 128 条；《最高人民法院关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》第 6 条

➤ [答题话术]

立案阶段	证明有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案。（《刑事诉讼法》第 112 条）
逮捕阶段	根据《高检规则》第 128 条可知，逮捕的证据标准如下：(1) <u>有证据证明发生了犯罪事实</u>

	实；（2）有证据证明该犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的；（3）证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已经查证属实。
侦查终结 审查起诉 审判阶段	根据《刑事诉讼法》第55条第2款， <u>证据确实、充分</u> ，应当符合以下条件： （1） <u>定罪量刑的事实都有证据证明</u> ； （2） <u>据以定案的证据均经法定程序查证属实</u> ； （3） <u>综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑</u> 。
疑罪从无 疑案从轻	（1）定罪证据不足，应当坚持 <u>疑罪从无原则</u> ，依法宣告被告人无罪。 （2）定罪证据确实、充分，但影响量刑的证据存疑的，应当坚持 <u>疑案从轻原则</u> ，量刑时作出有利于被告人的处理。

专题四、刑诉案例中的主体（人物线）

- 问题 44：请分析本案的管辖问题。
- [法条索引] 《刑法》第 19-28 条；《刑诉解释》第 1-26 条；《高检规则》第 13-23 条；《公安部规定》14-31 条
- [答题话术]

第一步	先做立案管辖判断，处理交叉管辖、并案管辖的特殊问题。 1. 公安机关管辖范围：若无特别规定，均由公安侦查。 2. 检察院自侦案件范围：（《刑事诉讼法》第 19 条第 2 款） （1）司法职权。（搜拘滥私逼；暴虐枉玩执；放假监脱逃。） （2）机动侦查权。（公-机-权-大-省以上） 3. 法院自诉案件范围：亲告、轻微、公转自。（《刑诉解释》第 1 条） 4. 监察机关调查范围：贪、玩、滥、舞、责、其他。（《监察法》11、15 条） 5. 管辖竞合：该谁给谁。（《监察法》37、38 条、《高检规则》第 17、18 条） 6. 并案管辖：职责范围内并案。（《六机关规定》第 3 条、《刑诉解释》第 24、25、467 条）
第二步	接下来判断本案属哪个地域和哪个级别的侦查机关管辖。 1. 地域管辖：犯罪地为主，犯罪嫌疑人居住地为辅。（《公安部规定》第 15 条） 2. 级别管辖：（市级：危、恐、经、外、团、跨区）（《公安部规定》第 24 条） [关联法条]《高检规则》第 14 条
第三步	接下来判断侦查机关移送哪个人民检察院审查起诉。 一并移送<u>同级人民检察院</u>审查决定。（《刑事诉讼法》第 160 条）
第四步	接下来判断提起公诉的检察院。（《高检规则》第 328 条第 1 款） 各级人民检察院提起公诉，<u>应当与人民法院审判管辖相适应</u>。（门当户对，否则移送）
第五步	最后判断人民法院的审判管辖： 1. 法院的级别管辖： （1）中院：“危”“恐”“无”“死”“证”“没”“缺”（《刑法》第 21、291、299 条） （2）变通：上可审下，下不可审上，数罪就高不就低。（《刑诉解释》第 14-17 条） 2. 法院的地域管辖：（《刑事诉讼法》第 25、26 条）。 3. 特殊地域管辖：（《刑诉解释》第 2-13 条）。 4. 指定管辖： （1）管辖不宜；《刑诉解释》第 18 条 （2）管辖不明；《刑诉解释》第 20 条 （3）规避管辖；《刑诉解释》第 23 条

➤ 问题 45：境外电诈案的管辖问题。

➤ [法条索引]《刑法》第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条；《刑事诉讼法》第 25 条、第 26 条、第 27 条；《刑诉解释》第 2 条、第 10 条、第 11 条

➤ [答题话术]

属地管辖	缅北电诈虽然犯罪窝点设在境外，但如果诈骗对象主要是我国境内居民，被害人在我国境内接收诈骗信息、处分财产、遭受财产损失，犯罪结果发生在我国境内。根据《刑法》第 6 条，<u>犯罪行为或者结果有一项发生在我国领域内的，就认为是在我国领域内犯罪</u>。因此，跨境电诈案最稳的切入点通常不是“人在境外”，而是结果地在境内，适用<u>属地管辖</u>。 [记忆要点]犯罪地为主，被告人居住地为辅。
属人管辖	如果被告人系中国公民，即使其犯罪行为均发生在境外，只要其行为依照我国刑法构成犯罪，我国也可以根据《刑法》第 7 条行使属人管辖。审判管辖上，中国公民在我国领域外犯罪的，<u>由其登陆地、入境地、离境前居住地或者现居住地法院管辖</u>；被害人是<u>中国公民的</u>，也可以由被害人离境前居住地或者现居住地法院管辖。 [记忆要点]被告登陆入境地，双方都有现前管。
保护管辖	如果系外国人，且行为发生在境外，但其如果针对我国公民实施诈骗，侵害我国公民财产权益。则我国可以根据《刑法》第 8 条适用保护管辖。审判管辖上，外国人在我国领域外对我国国家或者公民犯罪的，<u>由该外国人登陆地、入境地或者入境后居住地法院管辖</u>，也可以由被害人离境前居住地或者现居住地法院管辖。 [记忆要点]被告登陆和两境，被害可有现前管。
网络犯罪	电诈属于典型的网络犯罪，犯罪地不仅包括传统的犯罪行为地、犯罪结果地，还包括用于实施犯罪行为的服务器所在地、网络服务提供者所在地、被侵害的信息网络系统所在地、犯罪过程中被告人和被害人使用的信息网络系统所在地、被害人被侵害时所在地、被害人财产遭受损失地等。 [记忆要点]沾边就管。

➤ 问题 46：被害人、自诉人在不同情形下的权利救济途径。

➤ [法条索引]《刑诉法》第 110、112、113、210、180、229、252、305、46、137、191。

➤ [答题话术]

被害人的 诉讼权利 归纳	1. 报案、控告：《刑事诉讼法》第 110 条
	2. 对于公安机关不立案的救济权：《刑事诉讼法》112、113、210 条 (1) 可以向原公安申请复议，对复议决定不服，可向上一级公安申请复核。 (2) 可以向同级检察院提出申诉。 (3) 可以向法院提出自诉。
	3. 对于检察院不起诉的救济：《刑事诉讼法》180 条 (1) 有权向上一级检察院要求申诉。 (2) 有权向法院提出自诉。
	4. 对于法院裁判结果不服的救济：《刑事诉讼法》第 229、252、305 条 (1) 对一审未生效判决，不能上诉，只能请求检察院抗诉。 (2) 对生效裁判，可以再审申诉。
	5. 委托诉讼代理人权利：《刑事诉讼法》第 46 条 有权自案件移送审查起诉之日起，委托诉讼代理人。
	6. 参加法庭调查、陈述意见、发问等权利。《刑事诉讼法》137、191 条
自诉人的	如果是自诉案件，自诉人的诉讼权利有别于被害人。

差异	[记忆要点]自诉人有起诉权、有撤诉权、有上诉权、有申诉权。
----	-------------------------------

- 问题 47：辩护人的诉讼权利。
- [法条索引]《刑法》第 38-43、49 条
- [答题话术]

阅卷权	[记忆要点]非律阅卷要许可；律师阅卷不用批；均自审查起诉起。 [法条索引]《刑事诉讼法》第 40 条。
会见通信	[记忆要点]非律会见要许可，律师一般不用批，危恐除外要许可，侦查律师可会见，核证等到下阶段。 [法条索引]《刑事诉讼法》第 39 条。
调查取证	[记忆要点]非律没有取证权；律师取证需同意；控方证人双重许；若有困难申请取。 [法条索引]《刑事诉讼法》第 43 条。
申诉控告	有权向同级或者上一级人民检察院申诉或者控告。 [法条索引]《刑事诉讼法》第 49 条。
侦查阶段权利清单	侦查阶段辩护律师可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；代理申诉、控告；申请变更强制措施；向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见；会见通信。 [记忆要点]侦查阶段的消极清单： <u>无阅卷、无核证、无非律</u> 。

- 问题 48：本案办案机关是否应当通知法律援助机构指派律师为犯罪嫌疑人、被告人提供法律援助辩护？既有法律援助辩护，又有委托辩护该如何处理？如果被告人拒绝辩护人辩护，法院该如何处理？
- [法条索引]《刑诉解释》47、48、50、51、311；《刑事诉讼法》35、278、293 条。
- [答题话术]

法援辩护	[记忆要点]强制法援辩护： <u>盲聋哑、半疯傻、死无缺（排）、未长大</u> 。 [法条索引]《刑诉解释》第 47、48；《刑事诉讼法》35、278、293 条。
辩护冲突	对法律援助机构指派律师为被告人提供辩护，被告人的近亲属又代为委托辩护人的，应当听取被告人的意见， <u>由其确定辩护人</u> 人选。
拒绝辩护	(1) 强制款： <u>有理+1 次+有人辩</u> (2) 普通款： <u>无理+2 次+自己辩</u> [法条索引]《刑诉解释》第 50 条、311 条

问题 49：根据案情材料，假如你是本案的辩护人，请写一份辩护意见或辩护词

[答题话术]

辩护思路	“罪”“责”“刑”“名”“过”“主从”；分析“证据”和“程序”
辩护词模板	被告人××涉嫌××罪一案 辩护词 审判长、审判员（人民陪审员）： 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第 34 条第 1 款的规定，××律师事务所接受本案被告人××（近亲属××）委托，指派我担任其一审辩护人，为被告人××进行辩护。庭前，辩护人研究了本案的起诉书，查阅卷宗材料，会见了被告人，对本案有了较清楚的了解。辩护人认为，被告人××不构成××罪，（或辩护人对公诉机关指控被告人××构成××罪没有异议，但对公诉机关的量刑意见持有异议）。为维护被告人××的合法权益，现发表如下辩护意见：

	……（辩护理由，此部分主要是写明辩护的理由、观点。辩护理由应该从起诉书指控的犯罪事实出发，围绕被告人是否构成犯罪、属于何种罪名、有无从轻处罚的法定条件以及诉讼程序是否合法等问题展开论述。辩护理由要求充分，于法有据，论证清晰。） 综上所述，……（此部分是对辩护词的归纳和小结。一是辩护词的内容核心，如无罪、罪轻等；二是向法庭提出对被告人的处理意见。） 辩护人：××× ××××年××月××日
--	--

- 问题 50：张三委托了向律师做辩护人，李四没有委托辩护人，办案机关通知了值班律师高律师为其提供法律帮助。同样是律师，辩护律师向某和值班律师高某有哪些不同。
- [法条索引]《法律援助值班律师工作办法》
- [答题话术]

（1） <u>二者设立的立法目的不同</u> 。值班律师制度的立法目的在于，确保认罪认罚案件中，犯罪嫌疑人、被告人对认罪认罚有关法律规定的理解，保证认罪认罚的自愿性和合法性，并帮助被告人作出程序选择。辩护律师制度是犯罪嫌疑人、被告人有权辩护的宪法原则和刑事诉讼法原则的具体体现。
（2） <u>二者在刑事诉讼中的地位 and 行使权利的性质不同</u> 。值班律师的诉讼地位是法律帮助人的地位，其行使的权利属于法律帮助权和咨询权。辩护律师的诉讼地位是辩护人的诉讼地位，其行使的权利是辩护权。
（3） <u>二者权利的大小和范围不同</u> 。值班律师制度是辩护律师制度的补充，只有在当事人没有辩护人的情况下，才由值班律师行使法律帮助权。值班律师的权利主要包括提供法律咨询、程序选择建议、申请变更强制措施、对案件处理提出意见。辩护律师享有广泛的诉讼权利，如出庭辩护、调查取证等。

- 问题 51：值班律师的职责以及权利范围。
- [法条索引]《法律援助值班律师工作办法》第 6、21、22 条
- [答题话术]

职责	（1）提供法律咨询； （2）提供程序选择建议； （3）帮助犯罪嫌疑人、被告人申请变更强制措施； （4）对案件处理提出意见； （5）帮助犯罪嫌疑人、被告人及其近亲属申请法律援助； （6）法律法规规定的其他事项。 [记忆要点]提供咨询出建议，申请变更提意见，申请法援和其他。
权限	（1）侦查阶段，值班律师可以向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名及案件有关情况。 （2）案件进入审查起诉阶段后，值班律师可以查阅案卷材料，了解案情。 （3）值班律师到看守所办理法律帮助会见手续，看守所应当及时安排会见。危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，侦查期间值班律师会见在押犯罪嫌疑人的，应当经侦查机关许可。

专题五、刑诉案例中的阶段（时间线）

1-立案阶段

- 问题 52：被害人报案称被人强奸，公安机关经初步调查认为目前证据不能证明谁是真凶，以证据不满足立案条件为由不予立案。

- [法条索引] 《刑事诉讼法》第 112 条
- [答题话术]

本案公安机关不立案决定不正确。

根据《刑事诉讼法》第 112 条规定，立案的条件如下：（1）证明有犯罪事实；（2）需要追究刑事责任。本案目前证据虽不能证明谁是真凶，但只要能证明有犯罪事实且需要追究刑事责任就符合立案条件。因此，公安机关不予立案是错误的。

- 问题 53：初查阶段能不能适用技术侦查措施？初步调查核实中收集的证据能否作为定案依据？
- [法条索引] 《办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第 12、13 条
- [答题话术]

初查手段	公安机关立案前的初查阶段， <u>适用了限制被调查对象人身、财产权利的措施或者技术侦查措施是违法的</u> 。根据《关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第 12 条规定，调查核实过程中，可以采取询问、查询、勘验、检查、鉴定、调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施， <u>不得对被调查对象采取强制措施，不得查封、扣押、冻结被调查对象的财产，不得采取技术侦查措施</u> 。
初查证据	根据《关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第 13 条规定，公安机关在 <u>调查核实过程中依法收集的电子数据等材料，可以根据有关规定作为证据使用</u> 。调查核实过程中收集的材料作为证据使用的，应当随案移送，并附批准调查核实的相关材料。调查核实过程中收集的证据材料 <u>经查证属实，且收集程序符合有关要求的，可以作为定案依据</u> 。

- 问题 54：公安机关决定不立案，不同诉讼主体的救济途径和检察院的监督方式。
- [法条索引] 《刑诉法》第 113 条；《刑诉解释》第 1 条；《公安部规定》179 条
- [答题话术]

被害人	1. 向公安机关复议、复核。（《公安部规定》第 179 条） 2. 向人民检察院申诉。（《刑事诉讼法》第 113 条） 3. 向法院提起自诉。（《刑诉解释》第 1 条第 3 项）
检察院	<u>应当要求公安说明不立案的理由</u> 。检察院认为公安机关不立案理由不能成立的， <u>应当通知公安立案</u> ，公安机关接到通知后应当立案。（《刑事诉讼法》第 113 条）

2-侦查、调查阶段

- 问题 55：本案侦查中有哪些程序违法？（9 种侦查手段和 5 种强制措施）
- [法条索引]

9 种侦查手段	讯问-询问-勘验、检查-搜查-查封、扣押、查询、冻结-鉴定-辨认-技术侦查-通缉 [法条索引] 《刑诉法》115-155 条；《公安部规定》191-297 条；《高检规则》176-236 条
5 种强制措施	拘传-取保候审-监视居住-拘留-逮捕 [法条索引] 《刑诉法》66-100 条；《公安部规定》78-168 条；《高检规则》81-155 条

- [命题提示] 案例中如果出现大量的侦查程序描述，有一种命题可能是要求同学们判断，通过违法的侦查程序收集的证据能否作为定案依据，考查证据的审查判断。该问题同学们可参照相应考点来作答。
- 问题 56：本案是否满足 XX 强制措施的适用条件。

- [法条索引]《刑事诉讼法》第 67 条、74 条、81 条；《公安部规定》第 82 条；《高检规则》第 128 条
- [答题话术]

取保候审适用条件	取保候审的条件： [记忆要点]积极条件：“徒刑以下”“不危险”“疾病、孕乳”“超期限”。
	禁止取保候审的情形 [记忆要点]消极条件：禁止“累”“主”“残”“暴”“严”；除非“疾病、孕乳”“超期限”。
监视居住适用条件	[记忆要点]监视居住替代逮捕情形：疾病、孕乳、唯一扶、特殊、需要、已超期。
	[记忆要点]监视居住替代取保候审情形：没钱又没人。
逮捕适用条件	[记忆要点]逮捕的三个基本条件可概括为：有证据、够徒刑、有危险。
	径行逮捕的条件：对有证据证明有犯罪事实，可能判处十年有期徒刑以上刑罚的，或者有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚， <u>曾经故意犯罪或者身份不明的</u> ，应当予以逮捕。
	转化型逮捕：被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人 <u>违反取保候审、监视居住的规定，情节严重的</u> ，可以予以逮捕。

- 问题 57：羁押必要性审查的主体、对象以及审查结果。
- [法条索引]《检察院 公安机关羁押必要性审查、评估工作规定》第 1、4、16、18 条
- [答题话术]

审查对象	[记忆要点]羁押必要性审查对象是 <u>被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人</u> 。
审查主体	[记忆要点]羁押必要性审查，由人民检察院的 <u>捕诉部门</u> 负责。
应当释放或变更的情形	审查后发现犯罪嫌疑人、被告人具有下列情形之一的，应当向公安机关、人民法院提出释放或者变更强制措施建议；审查起诉阶段的， <u>应当及时决定释放或者变更强制措施</u> 。 （一）案件证据发生重大变化， <u>没有证据证明有犯罪事实或者犯罪行为系犯罪嫌疑人、被告人所为的</u> ； （二）案件事实、情节或者法律、司法解释发生变化，犯罪嫌疑人、被告人 <u>可能被判处拘役、管制、独立适用附加刑、免于刑事处罚或者判决无罪的</u> ； （三）继续羁押犯罪嫌疑人、被告人，羁押期限将 <u>超过依法可能判处的刑期的</u> ； （四）案件事实基本查清，证据已经收集固定， <u>符合取保候审或者监视居住条件的</u> ； （五）其他对犯罪嫌疑人、被告人采取羁押强制措施不当，应当及时释放或者变更的。 公安机关评估后发现符合上述情形的，应当及时决定释放或者变更强制措施。 [记忆要点]应当及时释放或者变更的情形： <u>无证据、无徒刑、无必要、已超期</u> 。
禁止变更的情形	[记忆要点]禁止变更的情形： <u>危恐黑毒严；严重暴力犯；性侵未成年；贪贿侵人权；报证逃十转。除非疾病不宜不危险</u> 。

- 问题 58：本案的补充侦查程序有哪些违法之处？
- [法条索引]《刑法》90 条；《高检规则》第 342-346、422、423 条；《刑诉解释》第 274、277 条

批捕阶段	不批准逮捕的， <u>应当说明理由，需要补充侦查的</u> ，应当同时 <u>通知公安</u> 。（《刑法》第 90 条）
审查起诉	1. 补侦情形： <u>犯罪事实不清、证据不足或存在遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人等</u> 。 2. 补侦主体：（1） <u>退回公安、监委、自侦部门</u> ；（2）人民检察院自行侦查。 3. 补侦方式：制作（书面） <u>补充侦查提纲</u> ，连同案卷材料一并退回公安机关或自侦部门。 4. 退补次数： <u>2 次</u> 为限，每次 <u>1 个月</u> 。 5. 期间计算：补充调查、补充侦查完毕移送起诉后，人民检察院 <u>重新计算</u> 审查起诉期限。 ➤ [法条索引]《高检规则》第 342-346 条

审判阶段	1. 启动方式：<u>公诉人发现案件需要补充侦查，建议延期审理的，合议庭可以同意，但建议延期审理不得超过2次。但是，审判期间，被告人提出新的立功线索的，人民法院可以建议人民检察院补充侦查。</u>（《刑诉解释》第274、277条） 2. 补侦主体： （1）对于需要补充提供法庭审判所必需的证据或者补充侦查的，<u>检察院应当自行收集证据和进行侦查</u>，必要时可以要求监察机关或者公安机关提供协助。（《高检规则》第422条） （2）发现<u>遗漏同案犯罪嫌疑人或者罪行的，应当要求公安机关补充移送起诉或者补充侦查</u>；对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，可以直接追加、补充起诉。（《高检规则》第423条） 3. 补充侦查期限届满后，检察院未将补充的证据材料移送法院的，<u>法院可以根据在案证据作出判决、裁定。</u>（《刑诉解释》第274条第3款）
------	---

3-监察程序与刑诉程序的衔接

- 问题 59：某职务犯罪的调查程序中，监察机关适用了多种调查手段，同时对被调查人适用了留置措施，本案的调查程序中有哪些违法之处
- [法条索引]

调查手段	[命题分析]注意监委的调查手段：讯问、询问、查询、冻结、<u>搜查</u>、调取、查封、扣押、勘验检查、鉴定、<u>技术调查</u>、<u>通缉</u>、<u>限制出境</u>。 [法条索引]《监察法》第20-33、44条
强制到案	[法条索引]《监察法》第21、46条
责令候查	[法条索引]《监察法》第23条
管护手段	[法条索引]《监察法》第25、46条
留置手段	[命题分析]注意监委留置的<u>适用条件</u>、<u>审批程序</u>、<u>执行程序</u>。 [法条索引]《监察法》第24、47、48条

- 问题 60：简述监察程序与刑事诉讼程序的衔接问题。
- [法条索引]《监察法》第36、37、54、55条；《刑事诉讼法》第170条
- [答题话术]

管辖衔接	1. 国家机关在工作中发现公职人员涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务违法或者职务犯罪的问题线索，<u>应当移送监察机关，由监察机关依法调查处置。</u> 2. 被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪，又涉嫌其他违法犯罪的，<u>一般应当由监察机关为主调查，其他机关予以协助。</u> [关联法条]《高检规则》第17条
强制措施	对于监察机关移送起诉的已采取留置措施的案件，<u>人民检察院应当对犯罪嫌疑人先行拘留，留置措施自动解除。</u>（《刑事诉讼法》第170条第2款）
证据效力	监察机关收集的物证、书证、证人证言、被调查人供述和辩解、视听资料、电子数据等证据材料，<u>在刑事诉讼中可以作为证据使用。</u>（《监察法》第36条第1款）
补充调查	检察院经审查，认为需要补充核实的，<u>应当退回监察机关补充调查，必要时可以自行补充侦查。</u>对于补充调查的案件，应当在1个月内补充调查完毕。补充调查以2次为限。（《监察法》第54条第3款）
审查起诉	<u>经上一级检察院批准</u>，依法作出不起诉的决定。监察机关认为不起诉的决定有错误的，<u>可以向上一级检察院提请复议。</u>（《监察法》第54条第4款）
程序转化	监察机关在调查贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪案件过程中，被调查人<u>逃匿或者死亡</u>，有必要继续调查的，<u>应当继续调查并作出结论。</u>被调查人逃匿，在<u>通缉一年后不能到案</u>，或者死亡的，<u>由监察机关提请人民检察院依照法定程序，向人民法院提出没收违法所得的申请。</u>（《监

察法》第 55 条)

4-审查起诉阶段

- 问题 61：对退回二次补充侦查（调查）的案件，在审查起诉中又发现新的犯罪事实该如何处理？
- [法条索引]《高检规则》第 349 条
- [答题话术]

根据《高检规则》第 349 条规定，人民检察院对已经退回监察机关二次补充调查或者退回公安机关二次补充侦查的案件，在审查起诉中又发现新的犯罪事实，应当将线索移送监察机关或者公安机关。对已经查清的犯罪事实，应当依法提起公诉。本案，检察院应当将新罪的犯罪线索移送公安机关，对已经查清的犯罪，依法提起公诉。

- 问题 62：人民检察院在审查起诉中发现漏罪、漏人如何处理？
- [法条索引]《高检规则》第 356 条
- [答题话术]

根据《高检规则》第 356 条规定，人民检察院在办理公安机关移送起诉的案件中，发现遗漏罪行或者有依法应当移送起诉的同案犯罪嫌疑人未移送起诉的，应当要求公安机关补充侦查或者补充移送起诉。对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，也可以直接提起公诉。本案，检察院对于遗漏的 XX 犯罪事实或者同案犯 XX，在事实清楚、证据确实、充分的情况下，也可以直接提起公诉。

- 问题 63：人民检察院在审查起诉中发现案件的立案管辖分工存在错误，该如何处理？
- [法条索引]《高检规则》第 357 条
- [答题话术]

检察院查了监委的案	人民检察院立案侦查时认为属于直接受理侦查的案件，在 <u>审查起诉阶段</u> 发现属于监察机关管辖的，应当及时 <u>商</u> 监察机关办理。
检察院查了公安的案	人民检察院立案侦查时认为属于直接受理侦查的案件，在 <u>审查起诉阶段</u> 发现属于公安机关管辖，案件事实清楚，证据确实、充分，符合起诉条件的，可以直接起诉；事实不清、证据不足的，应当及时移送有管辖权的机关办理。（ <u>查清了就诉、没查清就送</u> ）
公安、监委查了对方的案	发现公安机关移送起诉的案件 <u>属于监察机关管辖</u> ，或者监察机关移送起诉的案件属于公安机关管辖，但案件事实清楚，证据确实、充分，符合起诉条件的，经征求监察机关、公安机关意见后， <u>没有不同意见的，可以直接起诉</u> ；提出不同意见，或者事实不清、证据不足的，应当将案件退回移送案件的机关并说明理由，建议其移送有管辖权的机关办理。（ <u>查清了且双方没意见就诉；否则退回建议移送</u> ）

- 问题 64：人民检察院决定不起诉，××不服该如何处理？
- [法条索引]《刑事诉讼法》第 179-181 条；《监察法》第 54 条
- [答题话术]

公安机关	认为不起诉的决定有错误的时候， <u>可以要求复议</u> ，如果意见不被接受，可以 <u>向上一级人民检察院提请复核</u> 。（《刑事诉讼法》第 179 条）
监察机关	认为不起诉的决定有错误的，可以 <u>向上一级人民检察院提请复议</u> 。（《监察法》第 54 条）
被害人	（1）可以自收到决定书后 7 日以内 <u>向上一级人民检察院申诉，请求提起公诉</u> 。 （2）被害人也可以 <u>直接向人民法院起诉</u> 。（《刑事诉讼法》第 180 条）
被不起诉人	对于人民检察院作出的 <u>酌定不起诉决定</u> ，被不起诉人如果不服，可以 <u>向该人民检察院申诉</u> 。（《刑事诉讼法》第 181 条）

- 问题 65：南医大女生被杀案，真凶 28 年后落网，本案如果已经超过最长追诉时效，请简述核准追诉的条件和核准程序。
- [法条索引]《高检规则》322-325
- [答题话术]

核准追诉条件	报请核准追诉的案件应当同时符合下列条件： 1.有证据证明存在犯罪事实，且犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的； 2.涉嫌犯罪的行为应当适用的法定量刑幅度的最高刑为无期徒刑或者死刑； 3.涉嫌犯罪的性质、情节和后果特别严重，虽然已过二十年追诉期限，但社会危害性和影响依然存在，不追诉会严重影响社会稳定或者产生其他严重后果，而必须追诉的； 4.犯罪嫌疑人能够及时到案接受追诉。
核准具体程序	1.公安机关报请核准追诉的案件，由同级人民检察院受理并层报最高人民检察院审查决定。 2.地方各级人民检察院对公安机关报请核准追诉的案件，应当及时审查并开展必要的调查。制作报请核准追诉案件报告书，连同案卷材料一并层报最高人民检察院。 3.最高人民检察院收到省级人民检察院报送的报请核准追诉案件报告书及案卷材料后，应当及时审查。经检察长批准，作出是否核准追诉的决定，并制作核准追诉决定书或者不予核准追诉决定书，逐级下达至最初受理案件的人民检察院，由其送达报请核准追诉的公安机关。

5-审判阶段

- 问题 66：公诉案件的庭前审查特点以及审查后的处理结果。
- [答题话术]

审查特点	庭前审查为书面的程序性审查，不做实质性审查。
审查结果	[记忆要点] 重点注意审查后应当退回检察院的几种情形：<u>管辖错、人不在、无新证再起诉、16 条 2-6。</u> [法条索引]《刑诉解释》第 219 条

- 问题 67：本案法院对多名被告人分案或并案审理是否妥当？
- [法条索引]《刑诉解释》第 220 条
- [答题话术]

分案审理	分案审理更有利于保障庭审质量和效率的，可以分案审理。
并案审理	合并审理更有利于查明案件事实、保障诉讼权利、准确定罪量刑的，可以并案审理。

- 问题 68：庭前会议相关程序。
- [法条索引]《庭前会议规程》
- [答题话术]

召开会议	依职权	法院可以决定召开庭前会议的情形： (1) 证据材料较多、案情重大复杂的； (2) 控辩双方对事实、证据存在较大争议的； (3) 社会影响重大的； (4) 需要召开庭前会议的其他情形。 [记忆要点]多、大、争议。
	依申请	控辩双方可以申请召开庭前会议，法院经审查认为有必要的，应当召开。
	强制开	辩方在开庭前申请排非并提供线索或材料的，法院应当召开庭前会议。
参会人员	应当参加	公诉人、辩护人应当参加庭前会议，检察官助理、律师助理可以协助。

	可以参加	根据案件情况， <u>被告人可以参加庭前会议</u> 。被告人 <u>申请参加庭前会议或者申请排除非法证据等情形</u> 的，法院应当通知被告人到场。 [命题分析]参加庭前会议是被告人的基本权利，申请必通知到场。
会议内容	了解情况 听取意见	庭前会议中，人民法院可以就与审判相关的问题 <u>了解情况，听取意见</u> ，依法处理管辖、回避、出庭证人名单、非法证据排除等可能导致庭审中断的事项， <u>组织控辩双方展示证据，归纳争议焦点，开展附带民事调解</u> 。 [命题分析]庭前会议不排非、不质证、不辩论。
	证据问题	(1) 对于控辩双方决定在庭审中出示的证据，法院 <u>可以组织展示有关证据并由证据出示方简要说明证据证明内容，听取另一方的意见，梳理存在争议的证据</u> 。对控辩双方在庭前会议中 <u>没有争议的证据，庭审时举证、质证可以简化</u> 。 (2) 对于 <u>明显事实不清、证据不足</u> 的案件， <u>可以建议人民检察院补充材料或者撤回起诉</u> 。建议撤回起诉的案件，人民检察院不同意的，开庭审理后，没有新的事实和理由，一般不准许撤回起诉。
会议效力		在庭前会议中 <u>达成一致意见以及人民法院依法作出处理决定的事项</u> ，法庭向控辩双方简要核实后 <u>当庭予以确认</u> ，除有 <u>正当理由</u> 外， <u>一般不再进行处理</u> 。 [命题分析]正当理由：新事实或新证据；程序违法；法律适用变化。

- 问题 69：控辩双方补充的和审判人员庭外调查核实取得的证据，是否必须经过当庭质证才能作为定案的根据？
- [法条索引]《刑诉解释》第 271 条
- [答题话术]

原则	对公诉人、当事人及其法定代理人、辩护人、诉讼代理人补充的和审判人员庭外调查核实取得的证据， <u>原则上应当经过当庭质证才能作为定案的根据</u> 。
例外	但是， <u>对不影响定罪量刑的非关键证据、有利于被告人的量刑证据以及认定被告人有犯罪前科的裁判文书等证据，经庭外征求意见，控辩双方没有异议的除外</u> 。本案中，有关于被告人自首立功的有利量刑证据，经庭外征求意见，控辩双方没有异议，不经过质证，可以作为定案依据。

- 问题 70：审判期间，公诉人申请出示开庭前未移送或者提交法院的证据，或者辩护方申请重新鉴定，法院又该如何处理？
- [法条索引]《刑诉解释》第 272、273 条
- [答题话术]

证据偷袭	公诉人申请出示开庭前未移送或者提交人民法院的证据，辩护方提出异议的，审判长应当 <u>要求公诉人说明理由；理由成立并确有出示必要的，应当准许</u> 。辩护方提出需要对新的证据作辩护准备的， <u>法庭可以宣布休庭，并确定准备辩护的时间</u> 。
重新鉴定	法庭审理过程中，辩护人 <u>申请重新鉴定的，应当说明申请重新鉴定的理由</u> 。 <u>法庭认为有必要的，应当同意，并宣布休庭；根据案件情况，可以决定延期审理</u> 。人民法院决定重新鉴定的，应当及时委托鉴定，并将鉴定意见告知人民检察院、当事人及其辩护人、诉讼代理人。

- 问题 71：审判期间的自首、立功的证据相关问题。
- [法条索引]《刑诉解释》第 277 条、第 73 条
- [答题话术]

材料未送	审判期间，合议庭发现被告人可能有自首、坦白、立功等法定量刑情节， <u>而人民检察院移送的案卷中没有相关证据材料的，应当通知人民检察院在指定时间内移送</u> 。人民检察院仍未移送的，人民法院 <u>应当根据在案证据对案件事实作出认定</u> 。
------	---

立功线索	审判期间，被告人提出新的立功线索的，人民法院可以建议人民检察院补充侦查。
------	--------------------------------------

- 问题 72：审判阶段，发现被告人还有新的犯罪事实的处理。
- [法条索引] 《刑诉解释》第 297 条、《高检规则》第 423 条
- [答题话术]

法院	审判期间，法院发现新的事实，可能影响定罪量刑的，或者需要补查补证的，应当通知人民检察院，由其决定是否补充、变更、追加起诉或者补充侦查。人民检察院不同意或者在指定时间内未回复书面意见的，法院应当就起诉指控的事实，依照本解释第 295 条的规定作出判决、裁定。（《刑诉解释》第 297 条）
检察院	发现遗漏同案犯罪嫌疑人或者罪行的，应当要求公安机关补充移送起诉或者补充侦查；对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，可以直接追加、补充起诉。（《高检规则》第 423 条）

- 问题 73：某贪污案审理中，被告人潜逃境外，法院该如何处理？
- [法条索引] 《刑事诉讼法》第 206、291、298 条
- [答题话术]

中止审理	《刑事诉讼法》第 206 条 在审判过程中，有下列情形之一的，致使案件在较长时间内无法继续审理的，可以中止审理：（一）被告人患有严重疾病，无法出庭的；（二）被告人脱逃的；（三）自诉人患有严重疾病，无法出庭，未委托诉讼代理人出庭的；（四）由于不能抗拒的原因。
缺席审判	《刑事诉讼法》第 291 条第 1 款 对于贪污贿赂犯罪案件，以及需要及时进行审判，经最高人民检察院核准的严重危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人在境外，监察机关、公安机关移送起诉，人民检察院认为犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，可以向人民法院提起公诉。人民法院进行审查后，对于起诉书中明确的指控犯罪事实，符合缺席审判程序适用条件的，应当决定开庭审判。
没收程序	《刑事诉讼法》第 298 条 对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通缉一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。

- 问题 74：某诈骗案（冻结了大量赃款）的审理中，被告人死亡，该如何处理？
- [法条索引] 《刑诉解释》第 606 条、《刑事诉讼法》第 298 条
- [答题话术]

终止审理 缺席判决	人民法院受理案件后被告人死亡的，应当裁定终止审理；但有证据证明被告人无罪，经缺席审理确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。（《刑诉解释》第 606 条）
没收程序	犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。（《刑事诉讼法》第 298 条）

- 问题 75：自诉案件的审理特点
- [法条索引] 《刑诉法》212；《刑诉解释》323-331
- [答题话术]

可以调解	公诉转自诉不能调解。（《刑事诉讼法》第 212 条）
可以反诉	公诉转自诉不能反诉。（《刑诉解释》第 334 条）
和解撤诉	如果确属自愿的，应当准许。（《刑诉解释》第 329、331 条）
简易程序	可以简易，不能速裁。（《刑诉解释》第 327 条）
审限特殊	被告人被羁押的审限同公诉程序，被告人未被羁押的审限 6 个月。（《刑诉法》第 212 条）

有可分性	(1) 多名被告人，可以只告部分人； (2) 多名自诉人，可以只有部分人告。（《刑诉解释》第 323 条）
------	--

➤ [记忆要点] 可调可反诉，除了公转自；可简可撤又可分，审限关键看押。

➤ 问题 76：简易程序和速裁程序有哪些区别。

➤ [法条索引]

简易程序	《刑事诉讼法》第 214-221 条；《刑诉解释》第 359-368 条
速裁程序	《刑事诉讼法》第 222-226 条；《刑诉解释》第 369-377 条

➤ [答题话术]

	速裁程序	简易程序
适用条件	轻微、清楚、认罪、同意	清楚、认罪、同意
禁止范围	盲聋哑、半疯傻、影响大、无罪阿，未成年，民未达。	盲聋哑、半疯傻、影响大、无罪阿。
程序转化	无罪无责违意愿，否认疑难争议大。	无罪、无责、否认、不清。
审判组织	应当由审判员 1 人独任审判。	可能判 3 年以下刑罚的，可以合议，可独任； 可能判超过 3 年刑罚的，应当合议。
审理期限	受理后 10 日以内审结；可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至 15 日。	可能判 3 年以下刑罚的，应当在受理后 20 日以内审结；可能判超过 3 年刑罚的，可以延长至一个半月。
程序简化	一般不进行法庭调查、法庭辩论。但应听取辩护人意见和被告人的最后陈述。	可以摘要宣读起诉书，讯问、发问可以简化或者省略。
宣判方式	应当当庭宣判。	一般应当当庭宣判。

➤ 问题 77：根据案情，本案应当作出何种裁判？

➤ [法条索引] 《刑诉解释》第 295 条

对第一审公诉案件，人民法院受理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：
(一)
(二) 起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，但指控的罪名不当的，应当依据法律和审理认定的事实作出有罪判决；
(三)
(四) 证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；
(五) 案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；
(六) 被告人因未达到刑事责任年龄，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；
(七) 被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；被告人符合强制医疗条件的，应当依照本解释第 26 章的规定进行审理并作出判决；
(八) 犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；
(九) 属于告诉才处理的案件，应当裁定终止审理，并告知被害人有权提起自诉；
(十) 被告人死亡的，应当裁定终止审理；但有证据证明被告人无罪，经缺席审理确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。
对涉案财物，人民法院应当根据审理查明的情况，依照本解释第 18 章的规定作出处理。
具有第 1 款第 2 项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以再次开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪及如何量刑进行辩论。

[答题话术]

第一步	本案综合全案证据，尚未达到事实清楚、证据充分的定罪标准，应当判决被告人无罪。
-----	--

亮观点	
第二步 大前提	根据《刑事诉讼法》第 55 条第 2 款，证据确实、充分，应当符合以下条件：（1） <u>定罪量刑的事实都有证据证明</u> ；（2） <u>据以定案的证据均经法定程序查证属实</u> ；（3） <u>综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑</u> 。
第三步 小前提	本案证据分析如下： 证据 1： 证据 2： 证据 3：
第四步 下结论	综上所述，本案定案的证据没有形成完整证据链， <u>没有达到证据确实、充分的证明标准，不能排除合理怀疑</u> 。根据 <u>疑罪从无</u> 的原理，根据 <u>证据裁判原则</u> 的要求，不能确定被告人有罪，应当做无罪判决。

- 问题 78：本案中哪些主体有权启动二审？
- [法条索引]《刑事诉讼法》第 227-229 条
- [答题话术]

上诉主体	1. <u>被告人、自诉人及其法定代理人</u> ，不服地方各级人民法院第一审的判决、裁定， <u>有权用书状或者口头向上一级人民法院上诉</u> 。被告人的 <u>辩护人和近亲属</u> ，经被告人同意，可以提出上诉。 2. <u>附带民事诉讼的当事人和他们的法定代理人</u> ，可以对地方各级人民法院第一审的判决、裁定中的附带民事诉讼部分，提出上诉。
抗诉主体	<u>地方各级人民检察院认为本级</u> 人民法院第一审的判决、裁定确有错误的时候， <u>应当向上一级人民法院提出抗诉</u> 。 [关联法条]《高检规则》第 589 条 1.上一级认为下级抗诉 <u>正确的</u> ，应当 <u>支持抗诉</u> 。 2.上一级认为下级抗诉 <u>不当的</u> ，应当听取下级人民检察院的意见。听取意见后，仍然认为抗诉不当的，应当向同级法院撤回抗诉，并且通知下级人民检察院。 3.发现下级检察院 <u>应当提出抗诉而没有提出抗诉</u> 的案件， <u>可以指令下级人民检察院依法提出抗诉</u> 。 4.上一级人民检察院 <u>支持或者部分支持抗诉意见的</u> ， <u>可以变更、补充抗诉理由，及时制作支持抗诉意见书，并通知提出抗诉的人民检察院</u> 。
请求抗诉	<u>被害人及其法定代理人</u> 不服地方各级人民法院第一审的判决的，自收到判决书后 5 日以内，有权请求人民检察院提出抗诉。

- 问题 79：二审程序中撤回上诉、抗诉，法院该如何处理？
- [法条索引]《刑诉解释》第 383、385 条
- [答题话术]

撤回上诉	1. 上诉人在 <u>上诉期限内</u> 要求撤回上诉的，人民法院 <u>应当准许</u> 。 2. 上诉人在 <u>上诉期满后</u> 要求撤回上诉的，第二审人民法院经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许； <u>认为原判确有错误的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理</u> 。（见错不许撤）
撤回抗诉	1. 人民检察院在 <u>抗诉期限内</u> 要求撤回抗诉的，人民法院应当准许。 2. 人民检察院在 <u>抗诉期满后</u> 要求撤回抗诉的，第二审人民法院 <u>可以裁定准许，但是认为原判存在将无罪判为有罪、轻罪重判等情形的，应当不予准许，继续审理</u> 。（判重不许撤）

- 问题 80：上诉不加刑原则
- [法条索引]《刑诉解释》第 401-403 条
- [答题话术]

概念表述	第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受限制。
对谁加刑	人民检察院只对部分被告人的判决提出抗诉，或者自诉人只对部分被告人的判决提出上诉的，第二审人民法院不得对其他同案被告人加重刑罚。 [记忆要点]被上、被抗可加刑，其他通通不加刑。
何为加刑	1. 原判认定的罪名不当的，可以改变罪名，但不得加重刑罚或者对刑罚执行产生不利影响； 2. 原判认定的罪数不当的，可以改变罪数，并调整刑罚，但不得加重决定执行的刑罚或者对刑罚执行产生不利影响； 3. 原判判处的刑罚畸轻，必须依法改判的，应当在第二审判决、裁定生效后，依照审判监督程序重新审判。 [记忆要点]刑期不变长、刑种不变多、方法不变严、罪名可改刑不变，数罪不加总刑期，如果非要加，只能走审监。
不变相加刑	1. 被告人或者其法定代理人、辩护人、近亲属提出上诉，人民检察院未提出抗诉的案件，第二审人民法院发回重新审判后，除有新的犯罪事实且人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院不得加重被告人的刑罚。 [记忆要点]重审不能变相加，除非新事补充诉。 2. 原审人民法院对上诉发回重新审判的案件依法作出判决后，人民检察院抗诉的，第二审人民法院不得改判为重于原审人民法院第一次判处的刑罚。 [记忆要点]原审没抗重审抗，可加不可超原审。

- 问题 81：人民检察院以一审量刑过重为由提出抗诉的情况下，二审法院加重被告人的量刑，是否违反了上诉不加刑原则？请从现行法律规定以及法理角度分别加以评价。
- [法条索引]《刑事诉讼法》第 237 条
- [答题话术]

法律上合法	从现行《刑事诉讼法》第 237 条第 2 款的规定来看，本案在人民检察院提出抗诉的情况下加重被告人的刑罚，并没有违反现行法律的规定。
法理上不合理	但是从立法精神分析，本案的处理违背了上诉不加刑原则的立法精神。根据“禁止不利变更”的法理，二审法院不得主动做出对被告人不利之变更。在检察机关支持被告人抗诉求轻的情况下，法院二审反向作出重判，虽然具备现时的“合法性”，但正当性与合理性不足。控诉方支持被告人，要求从轻处罚，而法院从重判处，势必形成法院既为裁判机关，又为控诉者的“自诉自审”现象，有违一般程序公正法理。
综上所述	在现行法律框架下，认为本案二审判决加重刑罚违反了上诉不加刑原则于法无据，该判决应当是“合法”的。至于从法理上分析的其所存在的不合理问题，应当通过推动完善法律，区分“有利抗诉”和“不利抗诉”来解决。

- 问题 82：本案二审法院审理后如何裁判？
- [法条索引]《刑法》第 236、238 条；《刑诉解释》第 404 条第 2 款
- [答题话术]

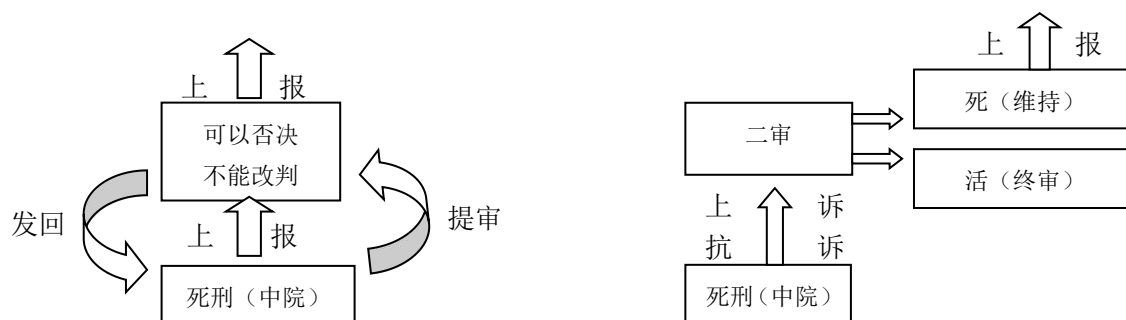
二审结果	1. 原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误或者量刑不当的，应当改判。 2. 原判决事实不清楚或者证据不足的，既可以查清依法改判，也可以裁定撤销原判，发回重审。
------	--

	3. 原判违反法定程序，应当裁定撤销原判，发回重审。
部分不清	有多名被告人的案件，部分被告人的犯罪事实不清、证据不足或者有新的犯罪事实需要追诉，且有关犯罪与其他同案被告人没有关联的，第二审人民法院根据案件情况， <u>可以对该部分被告人分案处理，将该部分被告人发回原审人民法院重新审判。</u> 原审人民法院重新作出判决后，被告人上诉或者人民检察院抗诉，其他被告人的案件尚未作出第二审判决、裁定的，第二审人民法院可以并案审理。

- 问题 83：死刑复核之中院一审判决被告人死刑立即执行，简述本案中院、高院分别该如何处理？
- [法条索引] 《刑诉解释》第 423 条
- [答题话术]

上诉抗诉	被告人 <u>上诉</u> 或者人民检察院 <u>抗诉</u> ，高级人民法院 <u>二审</u> 裁定维持的，应当在作出裁定后 10 日以内报请最高人民法院核准。
不上不抗	被告人 <u>未上诉</u> 、人民检察院 <u>未抗诉</u> 的，在上诉、抗诉期满后 10 日以内报请高级人民法院复核。高级人民法院同意判处死刑的，应当在作出裁定后 10 日以内报请最高人民法院核准； <u>不同意判处死刑的，应当依照第二审程序提审或者发回重新审判。</u>

[记忆图示]



- 问题 84：死刑复核之本案最高院对死刑复核后应当如何处理？
- [法条索引] 《刑诉解释》第 429 条
- [答题话术]

没错核准	原判认定事实和适用法律正确、量刑适当、诉讼程序合法的，应当裁定核准。
瑕疵纠正	原判认定的某一具体事实或者引用的法律条款等存在瑕疵，但判处被告人死刑并无不当的，可以在纠正后作出核准的判决、裁定。
见错发回	(1) 原判事实不清、证据不足的，应当裁定不予核准，并 <u>撤销原判，发回重审</u> ； (2) 复核期间出现新的影响定罪量刑的事实、证据的，应当裁定不予核准，并 <u>撤销原判，发回重新审判</u> ； (3) 原判认定事实正确、证据充分，但 <u>依法不应当判处死刑的</u> ，应当裁定不予核准，并 <u>撤销原判，发回重新审判</u> ； (4) 原审 <u>违反法定诉讼程序</u> ，可能影响公正审判的，应当裁定不予核准，并 <u>撤销原判，发回重新审判</u> 。
不死必要时可改	原判认定事实正确、证据充分，但 <u>依法不应当判处死刑的</u> ，应当裁定不予核准，并撤销原判，发回重新审判；根据案件情况， <u>必要时，也可以依法改判。</u>

- 问题 85：最高院不予核准死刑，发回哪个法院审理？如果发回高院，高院可否再发回中院？

- [法条索引]《刑诉解释》第 430、431 条
- [答题话术]

发回哪里	最高人民法院裁定不予核准死刑的，根据案件情况，可以发回 <u>第二审</u> 人民法院或者 <u>第一审</u> 人民法院重新审判。（《刑诉解释》430 条第 1 款）
发回二审	最高院发回二审法院重新审判的案件，第 <u>二审人民法院一般不得发回第一审人民法院重新审判</u> 。（《刑诉解释》430 条第 2 款）
发回复核	高院依照复核程序审理后报请最高院核准死刑，最高院裁定不予核准，发回高院重新审判的， <u>高院可以依照二审提审或发回重新审判</u> 。（《刑诉解释》431 条）

- 问题 86：如果中院一审判决被告人死刑缓期两年执行，高院针对本案该如何处理？
- [法条索引]《刑法》第 237 条、《刑诉解释》第 428 条
- [答题话术]

二审	中院判死缓没有限制减刑的一审案件，如果检察院 <u>抗诉</u> 的，高院 <u>二审</u> 认为应当限制减刑的，应当依法改判。 [记忆要点]二审程序：被上被抗可加刑。
复核	中院判死缓没有限制减刑的一审案件，被告人不上诉，检察院不抗诉的，中院 <u>上报</u> 高院 <u>复核</u> 认为应当限制减刑的， <u>不得对被告人限制减刑</u> 。 [记忆要点]复核程序：死缓复核不加刑（ <u>变轻容易变重难</u> ）。

- 问题 87：裁判生效后，哪些人可以申诉？简述向法院、检察院的申诉途径。
- [法条索引]《刑诉解释》第 451、453、455、459 条、《高检规则》第 593、594 条
- [答题话术]

申诉主体	当事人及其法定代理人、近亲属以及案外人对已经发生法律效力 ¹ 的判决、裁定提出申诉的，人民法院应当审查处理。 [记忆要点]申诉主体：当、法、近、外
向法申诉	1.申诉由 <u>终审</u> 人民法院审查处理。但是，第二审人民法院裁定 <u>准许撤回上诉</u> 的案件，申诉人对 <u>第一审</u> 判决提出申诉的， <u>可以由第一审人民法院审查处理</u> 。 2.上一级人民法院对未经终审人民法院审查处理的申诉， <u>可以告知申诉人向终审人民法院提出申诉，或者直接交终审人民法院审查处理，并告知申诉人</u> ；案件疑难、复杂、重大的， <u>也可以直接审查处理</u> 。 3.对未经终审人民法院及其上一级人民法院审查处理， <u>直接向上级人民法院申诉</u> 的，上级人民法院应当告知申诉人向 <u>下级人民法院</u> 提出。 4.对死刑案件的申诉， <u>可以由原核准的人民法院直接审查处理，也可以交由原审人民法院审查</u> 。原审人民法院应当制作审查报告，提出处理意见， <u>层报原核准的人民法院审查处理</u> 。 5.申诉人对驳回申诉不服的，可以向上一级人民法院申诉。上一级人民法院经审查认为申诉不符合规定的，应当说服申诉人撤回申诉； <u>对仍然坚持申诉的，应当驳回或者通知不予重新审判</u> 。
向检申诉	1.当事人及其法定代理人、近亲属认为人民法院已经发生法律效力 ² 的判决、裁定确有错误，向人民检察院申诉的， <u>由作出生效判决、裁定的人民法院的同级人民检察院依法办理</u> 。 2.当事人及其法定代理人、近亲属 <u>直接向上级人民检察院申诉</u> 的， <u>上级人民检察院可以交由作出生效判决、裁定的人民法院的同级人民检察院受理</u> ；案情 <u>重大、疑难、复杂</u> 的，上级人民检察院可以直接受理。 3.当事人及其法定代理人、近亲属对人民法院已经发生法律效力 ³ 的判决、裁定提出申诉，经人民检察院复查决定不予抗诉后继续提出申诉的， <u>上一级人民检察院应当受理</u> 。 4.对不服人民法院已经发生法律效力 ⁴ 的判决、裁定的申诉， <u>经两级人民检察院办理且省级人民检</u>

	察院已经复查的， <u>如果没有新的证据，人民检察院不再复查，但原审被告入可能被宣告无罪或者判决、裁定有其他重大错误可能的除外。</u>
--	--

- 问题 88：本案裁判生效后，哪些主体有权启动再审？
- [法条索引]《刑事诉讼法》第 254 条、《刑诉解释》第 461 条
- [答题话术]

法院	1. <u>本院院长</u> 对本院已经生效的裁判，发现确有错误， <u>提交审判委员会讨论决定本院来审。</u> 2. <u>上级</u> 人民法院发现 <u>下级</u> 人民法院已经发生法律效力的判决、裁定确有错误的， <u>可以指令下级人民法院再审</u> ；原判决、裁定认定事实正确但适用法律错误，或者案件疑难、复杂、重大，或者有不 ^① 宜由原审人民法院审理情形的， <u>也可以提审。</u>
检察院	3. <u>最高人民检察院对各级人民法院</u> 已经发生法律效力的判决和裁定， <u>上级人民检察院对下级人民^②法院</u> 已经发生法律效力的判决和裁定，有权按照审判监督程序 <u>向同级人民法院提出抗诉。</u>

- 问题 89：再审的审理和裁判
- [模拟问题 1] 本案法院再审依据何种程序审理？
- [法条索引]《刑事诉讼法》第 256 条、254 条
- [答题话术]

1.如果原来是第一审案件，应当依照第一审程序进行审判，所作的判决、裁定，可以上诉、抗诉；
2.如果原来是第二审案件，或者是上级人民法院提审的案件，应当依照第二审程序进行审判，所作的判决、裁定，是终审的判决、裁定。
[关联法条]《刑事诉讼法》254 条第 4 款 人民检察院抗诉的案件， <u>接受抗诉的人民法院应当组成合议庭重新^③审理，对于原判决事实不清楚或者证据不足的，可以指令下级人民法院再审。</u>

- [模拟问题 2] 湖南省高院二审终审，裁判生效后，最高检向最高院再审抗诉，最高院如果认为本案事实不清、证据不足该如何处理？
- [法条索引]《刑事诉讼法》第 254 条第 4 款、《刑诉解释》第 472 条
- [答题话术]

谁来审？	根据《刑事诉讼法》第 254 条第 4 款规定，人民检察院抗诉的案件， <u>接受抗诉的人民法院应当组成合议庭重新^④审理，对于原判决事实不清楚或者证据不足的，可以指令下级人民法院再审。</u>
按几审？	本案已经过高院二审终审，因此无论最高院提审还是指令下级法院再审，均 <u>适用二审程序审理。</u>
怎么判？	再根据《刑诉解释》第 472 条规定， <u>依照第二审程序审理的案件，原判决、裁定事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判，也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。事实仍^⑤无法查清，证据不足，不能认定被告人有罪的，应当撤销原判决、裁定，判决宣告被告人无罪。</u>

专题六、刑诉案例中的民刑交叉

- 问题 90：附带民事诉讼的前提条件（以刑诉为前提，并不以定罪为前提）
- [法条索引]《刑诉解释》第 197 条
- [答题话术]

不够犯罪	人民法院认定公诉案件被告人的行为不构成犯罪，对已经提起的附带民事诉讼，经调解不能达成协议的， <u>可以一并作出刑事附带民事判决，也可以告知附带民事原告人另行提起民事诉讼。</u> [记忆要点] <u>公诉若无罪，附民可调可判可另诉；</u>
撤回公诉	人民法院准许人民检察院撤回起诉的公诉案件，对已经提起的附带民事诉讼，可以进行调解；不宜调解或者经调解不能达成协议的，应当 <u>裁定驳回起诉，并告知附带民事诉讼原告人可以另</u>

行提起民事诉讼。

[记忆要点] 公诉若撤回, 附民调、驳、另。

➤ 问题 91: 附带民事诉讼的赔偿范围

➤ [法条索引] 《刑诉解释》第 175、176、177、192 条

➤ [答题话术] 仅限因被告人的犯罪行为造成的实际、必然的物质损失。

精神损害 不赔	1. 被害人因人身权利受到犯罪侵犯或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的, 有权在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼。 2. 因受到犯罪侵犯, 提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的, 法院一般不予受理。 (《刑诉解释》第 175 条)
非法占有、 处置的财 产不赔	被告人非法占有、处置被害人财产的, 被害人提起附带民事诉讼的, 人民法院不予受理, 但人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔, 追缴、退赔的情况, 可以作为量刑情节考虑。 (《刑诉解释》第 176 条)
公权力侵 权不赔	国家机关工作人员在行使职权时, 侵犯他人人身、财产权利构成犯罪, 被害人或者其法定代理人、近亲属提起附带民事诉讼的, 人民法院不予受理, 但应当告知其可以依法申请国家赔偿。 (《刑诉解释》第 177 条)
人身伤害 犯罪的赔 偿范围	犯罪行为造成被害人人身损害的, 应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用, 以及因误工减少的收入。造成被害人残疾的, 还应当赔偿残疾生活辅助具费等费用; 造成被害人死亡的, 还应当赔偿丧葬费等费用。 (《刑诉解释》第 192 条) [记忆要点] 医护交康加误工, 残疾辅助死亡葬。

➤ 问题 92: 附带民事诉讼的当事人

➤ [模拟问题]

1. 共同犯罪案件中同案犯在逃, 法院能否追加其为附带民事诉讼的被告人?

2. 刑事被告人以外的附带民事诉讼被告人下落不明的, 又该如何处理?

➤ [法条索引] 《刑诉解释》第 181、195 条

➤ [答题话术]

共犯在逃	被害人或者其法定代理人、近亲属仅对部分共同侵害人提起附带民事诉讼的, 人民法院应当告知其可以对其他共同侵害人, 包括没有被追究刑事责任的其他共同侵害人, 一并提起附带民事诉讼, 但共同犯罪案件中同案犯在逃的除外。 (《刑诉解释》第 181)
民事被告 人下落不 明	刑事被告人以外的附带民事诉讼被告人下落不明, 或者用公告送达以外的其他方式无法送达, 可能导致刑事案件审判过分迟延的, 可以不将其列为附带民事诉讼被告人, 告知附带民事诉讼原告人另行提起民事诉讼。 (《刑诉解释》第 195 条)

➤ 问题 93: 刑事附带民事诉讼的后续程序

➤ [模拟问题 1] 刑事附带民事诉讼的二审程序。

➤ [法条索引] 《刑诉解释》第 407-409 条

➤ [答题话术]

效力分离	刑事附带民事诉讼案件, 只有附带民事诉讼当事人及其法定代理人上诉的, 第一审刑事部分的判决在上诉期满后即发生法律效力。应当送监执行的第一审刑事被告人是第二审附带民事诉讼被告人的, 在第二审附带民事诉讼案件审结前, 可以暂缓送监执行。 (《刑诉解释》第 408 条)
民上刑不上	第二审人民法院审理对附带民事部分提出上诉, 刑事部分已经发生法律效力的案件, 应当对全案进行审查, 第一审判决的刑事部分确有错误的, 依照审判监督程序对刑事部分

	<u>进行再审，并将附带民事部分与刑事部分一并审理。</u> （《刑诉解释》第409条）
刑上民不上	第二审人民法院审理对刑事部分提出上诉、抗诉，附带 <u>民事诉讼部分已经发生法律效力</u> 的案件，如果发现第一审判决或者裁定中的民事部分确有错误， <u>应当对民事部分按照审判监督程序予以纠正。</u> 《刑诉解释》第407条

- [模拟问题2]一审判被告人死刑，只有附带民事诉讼原告人上诉，二审法院能否对刑事判决一并审查处理？
- [答题话术]

本案二审法院对刑事部分不能一并审查。根据最高人民法院的相关批复，中级人民法院一审判处死刑的案件，被判处死刑的被告人未提出上诉，仅附带民事诉讼原告人提出上诉的，高院应当适用第二审程序对附带民事诉讼部分依法审理，并由同一审判组织对未提出上诉的被告人的死刑判决进行复核，作出是否同意判处死刑的裁判。

专题七、刑诉案例中的特别程序（程序转化）

- 问题94：本案能否对犯罪嫌疑人××适用附条件不起诉？不同主体对附条件不起诉不服如何救济？检察院考察后最终案件该如何处理？
- [法条索引]《刑事诉讼法》第282-284条、《高检规则》第469-476条
- [答题话术]

适用条件	<u>[记忆要点]小孩犯罪456，1年以下够起诉，悔过可以附条件。</u>
异议方式	1.公安机关可以 <u>要求复议、提请复核。</u> （《刑事诉讼法》第282条） 2. <u>被害人</u> 对检察院附条件不起诉的决定，可以向上级检察院申诉，但不可向法院自诉。（全国人大常委会《关于〈刑事诉讼法〉第271条第2款的解释》） 3. <u>未成年犯罪嫌疑人及其法定代理人</u> 对拟作出附条件不起诉决定 <u>提出异议的</u> ，人民检察院应当提起公诉。（《高检规则》第470条）
考察监督	[法条索引]《刑事诉讼法》第283条、《高检规则》第475、476条
处理结果	1.起诉。被附条件不起诉的未成年犯罪嫌疑人，在考验期内有下列情形之一的，人民检察院应当撤销附条件不起诉的决定，提起公诉：（1）实施新的犯罪或者发现决定附条件不起诉以前还有其他犯罪需要追诉的；（2）违反治安管理规定或者考察机关有关附条件不起诉的监督管理规定，情节严重的。（漏罪、新罪、违法、违规） 2.不起诉。被附条件不起诉的未成年犯罪嫌疑人，在考验期内没有上述情形，考验期满的，人民检察院应当作出 <u>不起诉的决定</u> 。

- 问题95：本案人民法院在适用未成年人诉讼程序上有哪些程序违法？
- [答题话术]

分案原则	未成年人与成年人共同犯罪案件， <u>一般应当</u> 将未成年人与成年人分案起诉。但是具有下列情形之一的，可以不分案起诉：（1）未成年人系犯罪集团的组织者或者其他共同犯罪中的 <u>主犯</u> 的；（2）案件重大、疑难、复杂， <u>分案起诉可能妨碍案件审理的</u> ；（3）涉及刑事附带民事诉讼， <u>分案起诉妨碍附带民事诉讼部分审理的</u> ；（4）具有其他不宜分案起诉情形的。（《人民检察院办理未成年人刑事案件的规定》第51条）
不公开原则	<u>开庭审理时被告人不满18周岁</u> 的案件，一律不公开审理。（《刑诉解释》第557条）
讯问、询问	在讯问和开庭时， <u>应当通知未成年被告人的法定代理人到场</u> 。法定代理人无法通知、不能到场或者是共犯的， <u>也可以通知合适成年人到场</u> ，并将有关情况记录在案。 [命题分析1]根据《刑诉解释》第94条规定，讯问未成年人，其法定代理人或者合适成

	年人不在场的，该供述不能作为定案依据。 [命题分析] 根据《刑诉解释》第 90 条规定，询问未成年人，其法定代理人或者合适成年人不在场的，该陈述属于瑕疵证据，经补正或者作出合理解释的，可以采用；不能补正或者作出合理解释的，不得作为定案的根据。
一次询问原则	审理未成年人遭受性侵害或者暴力伤害案件，在<u>询问未成年被害人、证人时</u>，应当采取同步录音录像等措施，<u>尽量一次完成</u>；未成年被害人、证人是女性的，应当由女性工作人员进行。（《刑诉解释》第 556 条）
少年法庭	<u>犯罪时未满 18，法院立案时未满 20。</u>（《刑诉解释》第 550 条）
强制辩护	1. 没有委托辩护人的，<u>应当</u>通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。 2. 拒绝辩护重新开庭后，未成年被告人再次当庭拒绝辩护人辩护的，<u>不予准许</u>。但是重新开庭后，被告人已满 18 周岁的，再次当庭拒绝辩护人辩护的，<u>可以准许</u>，<u>但被告人不得再次另行委托辩护人或者要求另行指派律师，由其自行辩护</u>。 [法条索引] 《刑诉解释》第 564 条
简易程序	适用简易程序审理，<u>应当征求未成年被告人及其法定代理人、辩护人的意见</u>。 [命题分析] 未成年人案件可以用简易程序，但是<u>不能用速裁程序</u>。 [法条索引] 《刑诉解释》第 566 条
补充陈述	[法条索引] 《刑诉解释》第 577 条
公开宣判	[法条索引] 《刑诉解释》第 578 条
封存记录	[法条索引] 《刑事诉讼法》第 286 条、《高检规则》第 482、486、487 条
认罪认罚	1. 未成年犯罪嫌疑人认罪认罚的，在签署具结书时<u>应当有其法定代理人、辩护人在场</u>，未成年犯罪嫌疑人及其法定代理人、辩护人都对认罪认罚没有异议且愿意签署具结书的，应当签署具结书。 2. <u>法定代理人、辩护人对未成年人认罪认罚有异议的，不需要签署</u>认罪认罚具结书。 3. 未成年人认罪认罚案件，<u>不适用速裁程序</u>。

➤ 问题 96：本案能否适用公诉和解程序？

➤ [法条索引] 《刑事诉讼法》第 288 条、《高检规则》492 条

➤ [答题话术]

和解案件范围	(1) 因<u>民间纠纷引起</u>，涉嫌刑法分则第四、五章规定的犯罪案件，可能判处<u>3 年以下</u>刑罚； (2) 除渎职犯罪以外的可能判处<u>7 年有期徒刑以下</u>刑罚的<u>过失犯罪</u>案件。 [记忆要点] 民间人财 3 年下，7 年过失渎职外。 [命题分析] 以下几种情形不属于因民间纠纷引起的犯罪案件：(1) 雇凶伤害他人的；(2) 涉及黑社会性质组织犯罪的；(3) 涉及寻衅滋事的；(4) 涉及聚众斗殴的；(5) 多次故意伤害他人身体的；(6) 其他不宜和解的。
和解的条件	积极条件 [记忆要点] 你认错、他原谅、都愿意、侵特定、事实清。（《高检规则》第 492 条） 消极条件 <u>5 年以内曾经故意犯罪</u>的，不适用本章规定的程序。

➤ 问题 97-1：某交通肇事案，被告人认罪认罚，积极赔偿取得被害人谅解，本案如果适用公诉和解程序，公安机关能否撤销案件？法院能否判决无罪？检察院能否撤诉？

➤ [法条索引] 《刑事诉讼法》第 290 条、《刑诉解释》第 296 条、《高检规则》第 424 条

➤ [答题话术]

公安	对于达成和解协议的案件，<u>公安机关可以向检察院提出从宽处理的建议</u>。 [命题分析] 公安机关不能因和解而决定撤案。
----	--

检察院	可以向法院提出从宽处罚的建议;对于犯罪情节轻微,不需要判处刑罚的,可以作出不起起诉的决定。 [命题分析]检察院不能因和解而决定撤诉。
法院	人民法院可以依法对被告人从宽处罚。 [命题分析]法院不能因和解而判无罪。

- 问题 97-2: 达成公诉和解协议的案件,和解协议能否分期履行? 履行完毕的和解协议能否反悔?
- [法条索引] 《刑诉解释》第 592-595 条
- [答题话术]

签署协议	和解协议书应当由 <u>双方当事人和审判人员签名,但不加盖法院印章</u> 。(《刑诉解释》第 592 条)
履行协议	1. 和解协议约定的赔偿损失内容,被告人 <u>应当在协议签署后即时履行</u> 。(《刑诉解释》第 593 条) 2. 被害人或者其法定代理人、近亲属提起附带民事诉讼后,双方愿意和解,但被告人 <u>不能即时履行全部赔偿义务的,人民法院应当制作附带民事调解书</u> 。(《刑诉解释》第 595 条)
协议反悔	1. 和解协议已经全部履行,当事人反悔的,人民法院 <u>不予支持,但有证据证明和解违反自愿、合法原则的除外</u> 。(《刑诉解释》第 593 条) 2. 双方当事人在侦查、审查起诉期间已经达成和解协议并全部履行,被害人或者其法定代理人、近亲属又提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理,但有证据证明和解违反自愿、合法原则的除外。(《刑诉解释》第 594 条)

- 问题 98: 法院经审理如果认为被告人构成的并非指控的贪污罪,而是诈骗罪,该如何处理?
- [法条索引] 《刑诉解释》第 295、604 条
- [答题话术]

普通程序	对 <u>第一审公诉案件</u> ,人民法院审理后,认为起诉指控的事实清楚,证据确实、充分,但指控的罪名不当的,应当 <u>依据法律和审理认定的事实作出有罪判决</u> 。(《刑诉解释》第 295 条)
缺席审判	对人民检察院依照刑事诉讼法第 291 条第 1 款的规定提起公诉的案件,人民法院审理后应当参照本解释第 295 条的规定作出判决、裁定。经审理认定的罪名不属于刑事诉讼法第 291 条第 1 款规定的罪名的,应当 <u>终止审理</u> 。(《刑诉解释》第 604 条)

- 问题 99: 本案能否适用没收违法所得程序? 法院审理没收违法所得案件,该如何裁判? 利害关系人对处理结果不服该如何救济? 生效的没收裁定确有错误的又该如何处理?
- [法条索引] 《刑事诉讼法》第 298、300 条、《刑诉解释》第 622、628 条
- [答题话术]

适用条件	对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件,犯罪嫌疑人、被告人逃匿,在通缉一年后不能到案,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡,依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的,人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。
审理结果	1. 属于违法所得及其他涉案财产,除依法返还被害人的以外,应当 <u>裁定</u> 予以没收。 2. 不属于应当追缴的财产的,应当 <u>裁定</u> 驳回申请,解除查封、扣押、冻结措施。
救济途径	对没收违法所得或者驳回申请的裁定,犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人或者人民检察院可以在 5 日以内提出 <u>上诉、抗诉</u> 。
生效裁定	[命题分析 1] 裁定生效后,犯罪嫌疑人、被告人到案并对没收裁定提出异议,法院如何处理? 没收违法所得裁定生效后,犯罪嫌疑人、被告人到案并对没收裁定提出异议,人民检察院向

	原作出裁定的人民法院提起公诉的，法院经审理，应当按照下列情形分别处理：（1）原裁定正确的，予以维持，不再对涉案财产作出判决；（2）原裁定确有错误的，应当撤销原裁定，并在判决中对有关涉案财产一并作出处理。 [命题分析 2] 裁定生效后确有错误，犯罪嫌疑人、被告人没有到案，法院又该如何处理？ 人民法院生效的没收裁定确有错误的，<u>应当依照审判监督程序予以纠正</u>。
--	---

- 问题 100：故意杀人案审理中，被告人突发精神病，该如何处理？法院能否适用强制医疗程序？能否缺席审判？
- [法条索引] 《刑事诉讼法》第 206、302、296 条
- [答题话术]

中止审理	本案因被告人突发精神病，致使案件在较长时间内无法继续审理的，可以 <u>中止审理</u> （《刑事诉讼法》第 206 条）
强制医疗	本案 <u>不能适用强制医疗</u> 程序，根据《刑事诉讼法》第 302 条规定， <u>实施暴力行为，危害公共安全或者严重危害公民人身安全，经法定程序鉴定依法不负刑事责任的精神病人，有继续危害社会可能的</u> ，可以予以强制医疗。本案审理中被告人突发精神病，只是审理中的突发状况，并不属于 <u>不负刑事责任的精神病人的情形</u> 。
缺席审判	本案因被告人患有 <u>严重疾病无法出庭，中止审理超过六个月</u> ，被告人仍无法出庭，被告人及其法定代理人、近亲属 <u>申请或者同意恢复审理</u> 的，人民法院可以在被告人不出庭的情况下缺席审理，依法作出判决。（《刑事诉讼法》第 296 条）

温馨提示：

如果听完了《主观佛脚》还是不够自信，担心考场上遇到知识盲点，建议大家听听向老师的《主观法条定位课》。法条定位不是万能方法，它只有当你在考场上实在无能为力的时候，遇到考点盲区的时候，作为备用应试技能，替补登场。如果你考点储备足够，如果你答题表述流畅，建议直接作答，不要翻法条，它可能会浪费你的作答时间，况且是否引用相应法律条文并不是阅卷老师在意的采分点，所以希望大家不要过度迷信法条定位。当然，如果你考点储备不足，建议你听听这个法条定位课程，以备不时之需。表达过于白话的徒弟们，希望你多多引用法条，尽量掩饰自己的弱点，通过引用法条或概述条文内容让你的答题显得更加“专业化”。

各位提前规划好主观题听课计划：

1. 先听主观《真题破译》沙盘推演（已发布），熟悉主观命题规律和掌握主观题的答题技巧。
2. 再听主观题《采分有料》（已发布），背诵主观题的答题金句和模板。（成绩出来后，抓紧冲刺）
3. 免费下载《主观题佛脚》考前 100 问（已录制），储备主观题的考前弹药库。
4. 再听主观题《法条定位》（已录制），考前抓住最后一根救命稻草。